

Kap 8 Pflichtverletzungen im schuldrechtlichen (Austausch-)Vertrag – Grundlagen

© 2022 | Prof. Dr. Stefan Müller, Professur für Wirtschaftsrecht, insb. Innovations- und Technologierecht, Universität Paderborn

Lernziele des achten Kapitels:

Die Studierenden können...

- den Begriff der Pflichtverletzung im Rahmen von Schuldverhältnissen erläutern.
- verschiedene Kategorien von Pflichtverletzungen benennen und diese strukturell gegeneinander abgrenzen.
- mögliche Rechtsfolgen aus Pflichtverletzungen in bestehenden Schuldverhältnissen überblickartig darstellen und in diesem Kontext die Begriffe des Schadensersatzes, des Aufwendungsersatzes und des Rücktritts vom Vertrag erläutern.
- den Begriff der Unmöglichkeit der Leistung erklären, ihn anhand von Beispielen belegen, die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Unmöglichkeit nach dem BGB aufzeigen und diese anhand einfach gelagerter Sachverhalte nachvollziehen.
- Situationen der Verzögerung der Leistung benennen.
- die Leistungsstörungskategorie des Schuldnerverzugs (§ 286 BGB) darstellen und dessen Voraussetzungen und Rechtsfolgen anhand des BGB aufzeigen.
- die Verzögerung der Leistung in ihrer Bedeutung für den Fortbestand des vertraglichen Schuldverhältnisses, insbesondere unter den Aspekten des Rücktritts vom Vertrag sowie des Schadensersatzanspruchs statt der Leistung, beschreiben und anhand des BGB rechtlich einordnen.
- den Begriff des Fixgeschäfts erläutern, die verschiedenen Erscheinungsformen an Fixgeschäften gegeneinander abgrenzen und deren rechtliche Bedeutung anhand von Vorschriften des BGB und des HGB aufzeigen.
- die Bedeutung eines Gläubigerfehlverhaltens im Hinblick auf den vereinbarten Leistungszeitpunkt beschreiben, diese anhand der Vorschriften über den Gläubiger- bzw. Annahmeverzug im BGB und im HGB einordnen und an einfach gelagerten Sachverhalten nachvollziehen.

8.1 Pflichtverletzungen aus vertraglichen Schuldverhältnissen: ein Überblick	1
8.1.1 Begriff und Funktion der Pflichtverletzung	2
8.1.2 Kategorisierung möglicher Pflichtverletzungen	2
8.2 Mögliche Rechtsfolgen bei eintretenden Pflichtverletzungen	4
8.2.1 Das Erfüllungsbegehren des Gläubigers	5
8.2.2 Das Nacherfüllungsbegehren des Gläubigers	6
8.2.3 Das Schadensersatzbegehren des Gläubigers– Konzept, Voraussetzungen und Inhalt von Schadensersatzansprüchen	6
8.2.3.1 Das Schadensersatzkonzept des BGB hinsichtlich (vor-)vertraglicher Pflichtverletzungen	6
8.2.3.2 Ausgangspunkt: Die <i>allgemeinen</i> Voraussetzungen für die Entstehung von Schadensersatzansprüchen nach § 280 Abs. 1 BGB	7
8.2.3.3 Art, Inhalt und Umfang des Schadensersatzes (§§ 249 ff. BGB)	11
8.2.4 Aufwendungsersatzansprüche	13
8.2.5 Das Begehren des Gläubigers nach Auflösung des Vertrages	14
8.3 Die Unmöglichkeit der Leistung	14
8.3.1 Umstände, die zur Unmöglichkeit der Leistung führen	14
8.3.2 Rechtsfolgen der anfänglichen Unmöglichkeit	17
8.3.2.1 Die Behandlung der <i>Primäransprüche</i> (Leistung; Gegenleistung)	17
8.3.2.2 Die Behandlung etwaiger <i>Sekundäransprüche</i> bzw. -rechte	18
8.3.3 Rechtsfolgen der nachträglichen Unmöglichkeit	19
8.4 Verzugs- und Verzögerungssituationen	20
8.4.1 Die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs, § 286 BGB	21
8.4.1.1 Die Mahnung als regelmäßige Verzugsvoraussetzung	21
8.4.1.2 Vertretenmüssen und Verzugsseintritt	22
8.4.2 Rechtsfolgen des Schuldnerverzugs	23
8.4.2.1 Haftung auch für zufällig eintretende Leistungshindernisse, § 287 S. 2 BGB	23
8.4.2.2 Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen, § 288 BGB	23
8.4.2.3 Anspruch auf Ersatz von Verzugsschäden, § 280 Abs. 1 und 2 BGB	24
8.4.3 Der Einfluss der Verzögerung der Leistung auf den Fortbestand des (vertraglichen) Schuldverhältnisses	25
8.4.3.1 Das Rücktrittsrecht wegen Leistungsverzögerung	26
8.4.3.2 Schadensersatz statt der Leistung wegen Leistungsverzögerung	27
8.4.3.3 Fixgeschäfte	28
8.4.4 Die Voraussetzungen des Gläubigerverzugs	29
8.4.5 Die Rechtsfolgen des Gläubigerverzugs	30

II

8.4.5.1 Der Übergang der Leistungsgefahr nach § 300 Abs. 2 BGB.....	30
8.4.5.2 Veränderter Haftungsmaßstabs des Schuldners, § 300 Abs. 1 BGB	30
8.4.5.3 Ersatz von Mehraufwendungen, § 304 BGB	31
8.4.5.4 Weitere Rechtsfolgen nach BGB	31
8.4.5.5 <i>Ausblick</i> : Annahmeverzug im Handelskauf	31

Wenn die aus dem wirksam begründeten Austauschvertrag entstandenen Pflichten ordnungsgemäß erfüllt werden, erlöschen die (Primär-)Ansprüche, das Leistungsinteresse des Gläubigers wird befriedigt. Damit wird der Vertrag wie vereinbart abgewickelt und die wirtschaftliche Transaktion, die durch den Vertrag abgesichert werden sollte, wurde erfolgreich realisiert. Das sind die Kernaussagen von Kap. 7.

Im vorliegenden Kap. 8 soll hingegen untersucht werden, unter welchen Bedingungen es zu **Störungen bei der Abwicklung des Vertrages** kommen kann und welche rechtlichen Folgen solche Störungen nach sich ziehen können. Hinsichtlich der Rechtsfolgen geht es zum einen um das Schicksal des Anspruchs auf die Leistung bzw. des Anspruchs auf die Gegenleistung – beides Primäransprüche –, zum anderen um die mögliche Entstehung von Sekundäransprüchen und -rechten aus Anlass des Eintretens der Störung. Die nachfolgende Betrachtung setzt mit einigen grundlegenden, v. a. terminologischen Hinweisen zu den angesprochenen Störungen ein, die am Zentralbegriff des Leistungsstörungenrechts des BGB, der **Pflichtverletzung**, anknüpfen (unter 8.1). Überblickartig werden sodann unter 8.2 **mögliche Rechtsfolgen** von Pflichtverletzungen beleuchtet, bevor **ausgewählte Typen von Störungen** der Abwicklung des Vertrags näher dargestellt werden: Es sind dies die Unmöglichkeit der Leistung (unter 8.3), verschiedene Verzögerungssituationen (unter 8.4). *Beachte:* Weitere Fälle von Störungen bei der Durchführung von Verträgen allgemein werden aus Raumgründen zu Beginn von Kap. 9 behandelt, bevor im weiteren Verlauf des Kap. 9 gezielt der Kaufvertrag betrachtet wird.

8.1 Pflichtverletzungen aus vertraglichen Schuldverhältnissen: ein Überblick

Durch den wirksamen Abschluss eines Schuldvertrages werden **Pflichten** begründet, die vom Schuldner der Pflicht ordnungsgemäß zu erfüllen sind. Der Inhalt der Pflichten kann sehr unterschiedlich sein:

Beispiele: Pflicht des Verkäufers zur Übereignung eines Fahrrads an den Käufer gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB (Leistungspflicht, hier aus Kaufvertrag); – Pflicht des Käufers zur Zahlung des Kaufpreises an den Verkäufer (Gegenleistungspflicht; aus Kaufvertrag); – Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Rechtsgüter des anderen Teils im Zuge der Abwicklung des Vertrages (Schutzpflicht gem. § 241 Abs. 2 BGB, hier bei der Abwicklung eines vertraglichen Schuldverhältnisses i. S. des § 311 Abs. 1 BGB); – Pflicht einer Partei eines Zivilprozesses zur Unterlassung näher bezeichneten Wettbewerbs gegenüber der anderen Prozesspartei durch gerichtlichen Vergleich. Ein solcher Prozessvergleich ist zugleich materiell-rechtlich ein Vertrag, vgl. dazu § 779 BGB; die angesprochene Unterlassungspflicht ist quasi eine „negative“ Leistungspflicht.

8.1.1 Begriff und Funktion der Pflichtverletzung

Soweit eine Vertragspartei einer ihr obliegenden Pflicht nicht ordnungsgemäß nachkommt, ist zu fragen, ob dadurch – objektiv betrachtet – eine Pflicht verletzt wurde. Der Begriff der **Pflichtverletzung** ist seit 2002 der *zentrale Begriff* im BGB im Kontext der Störung bei der Abwicklung vertraglicher Schuldverhältnisse, der in einigen gesetzlichen Vorschriften aufgegriffen wird.

Zur historischen Einordnung: Früher wurde der in Kap. 8 des Skripts dargestellte Inhalt als sog. Leistungsstörungenrecht bezeichnet. Dies ist verkürzend. Der jetzt in den Mittelpunkt gerückte Begriff der **Pflichtverletzung** ist besser geeignet, die Vielfalt möglicher Pflichten zur Anschauung zu bringen, da er nicht zu einer terminologischen Verengung auf Leistungspflichten nötigt, sondern auch Nicht-Leistungspflichten erfassen kann.

Adressat der Pflicht ist der Schuldner derselben. Es liegt an ihm, für deren ordnungsgemäße Erfüllung zu sorgen. Ausnahmsweise kann die ordnungsgemäße Pflichterfüllung jedoch an einem Fehlverhalten des Gläubigers scheitern, falls nämlich der Gläubiger die ihm gegenüber korrekt angebotene Leistung aus Gründen nicht annimmt, die in seinem Einflussbereich liegen, oder er an der Erfüllung nicht mitwirkt, obwohl sein Zutun erforderlich ist. Da die Pflicht *gegenüber dem Gläubiger* zu erbringen ist, bedeutet ein Fehlverhalten des Gläubigers selbst terminologisch keine Pflichtverletzung, denn er darf die Erfüllung der Pflicht verlangen. Jedoch ist ein Gläubigerfehlverhalten im Hinblick auf die Annahme der Leistung – vgl. dazu den Annahmeverzug in §§ 293 ff. BGB – aus Anlass der Pflichtverletzungen darzustellen; dies im Bewusstsein, dass auch der Annahmeverzug letztlich eine Störung „bei der Erbringung der Leistung“ darstellt.

Ergänzender Hinweis: Der Begriff der Pflichtverletzung hat sich mittlerweile etabliert und das Gläubigerfehlverhalten durch Annahmeverzug kann als *Annex* zu einer Verletzung von Pflichten wegen Verzögerung dargestellt werden, vgl. dazu später unter 8.4.4.

Ob der Schuldner eine – objektiv vorliegende – Pflichtverletzung auch auf subjektiver Ebene *zu vertreten* hat oder nicht (vgl. §§ 276-278 BGB), ist für einzelne Rechtsfolgen aus Pflichtverletzungen in unterschiedlichem Maße relevant.

Ergänzung: Soweit das individuelle Vertretenmüssen der Pflichtverletzung durch den Schuldner im Einzelfall maßgeblich ist, sei auf die Darstellung unter 8.2.3.2 ad [3] verweisen. Dort wird untersucht, *was* ein Schuldner im Einzelnen zu vertreten hat.

8.1.2 Kategorisierung möglicher Pflichtverletzungen

Für eine grobe Orientierung zur Einordnung möglicher Pflichtverletzungen bietet sich eine Anknüpfung am Zeitpunkt des *Abschlusses* des Vertrages an (vgl. dazu Kap. 5 und 6). Soweit bereits zu diesem Zeitpunkt feststeht, dass eine Pflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt werden kann, liegt, **anfängliche** Pflichtverletzung vor. Falls

die Pflichtverletzung erst zu einem Zeitpunkt *nach* Vertragsschluss eintritt, spricht man von **nachträglicher** Pflichtverletzung. Vgl. zu alledem folgende Abbildung:

Das vertragliche (Austausch-) Schuldverhältnis im Laufe der Zeit Eintritt der Störung...			
...vor Vertragsschluss: bei <u>erfolgt</u>m Vertragsschluss: Anfängliche Unmöglichkeit, Sonderregel § 311 a BGB - Abs. 1: Vertrag ist wirksam - Abs. 2: spezieller Schadensersatzanspruch <u>ohne vorgenommenen</u> Vertragsschluss: bei Pflichtverletzung unter Umständen Schadensersatzanspruch nach §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB	... nach Vertragsschluss:		
	nachtr. Unmögl. d. L.	Verzögerung d. L.	„Schlechtleistung“
	Lstg wird überhaupt nicht erbracht, da nicht möglich	Mögl. Lstg wird nicht rechtzeitig erbracht (bzw. nicht rechtzeitig angenommen)	Lstg wird nicht in rechter Art/Weise erbracht (bzw. Verletzung einer Lstgs*bezog. Nebenpfl.)
	Ferner: Verletzung nicht leistungsbez. Nebenpflichten (§ 241 II BGB)		
	Bestehende Primäransprüche:		
	Erlöschen immer (Lsg)/ im Regelfall (Gegenlsg): § 275 Abs. 1 § 326 Abs. 1 BGB	bleiben grds. erhalten	bleiben grds. erhalten
Entstehende Sekundärrechte: SchErs nach § 280 Abs. 1 BGB, ggfs. erweitert nach Abs. 2,3 inkl. Verweisung Aufwendungsersatz (§ 284 Abs. 1 BGB (anstelle von SchErs statt der Leistung)) Rücktrittsrechte (vgl. §§323,324,326 Abs. 5 mit der Folge der §§ 346 ff. BGB) Ggfs. Weitere besondere Rechte in Abhängigkeit von der jeweiligen Leistung			

Abbildung: Überblick Störungskategorien nach Zeitpunkten

Folgende Umstände, die **vor** Vertragsschluss eintreten, können zu einer Pflichtverletzung führen:

- hinsichtlich der Leistungspflicht: Falls die Pflicht definitiv nicht erfüllt werden kann, liegt ein Fall sog. **anfänglicher Unmöglichkeit** vor; vgl. dazu unten 8.3.2.
- Die Entstehung von Rücksichtnahme- und Schutzpflichten hängt hingegen nicht von einem Vertragsschluss ab, Vorvertragliche Schadensersatzansprüche nach § 280 Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 311 Abs. 2, 3 und 241 Abs. 2 BGB (vgl. dazu Kap. unter 7.2) sind daher möglich.

Nach Abschluss des Vertrages sind deutlich *mehr* Kategorien denkbarer Pflichtverletzungen zu berücksichtigen:

- Die Unmöglichkeit der Leistung kann auch durch einen Umstand begründet werden, der nach Abschluss, jedoch vor vollständiger Erfüllung des Vertrages eintritt, vgl. dazu die, insbesondere in § 275 BGB sowie sogleich unter 8.3.
- Wenn die – an sich (noch) mögliche – Leistung nicht fristgerecht erbracht wird, kann eine Pflichtverletzung *in Ansehung der Leistungszeit* vorliegen, die zu unterschiedlichen Rechtsfolgen unter dem Gesichtspunkt des **Verzugs** (Schuldnerverzug, §§ 286 ff., bzw. Gläubigerverzug, §§ 293 ff. BGB) bzw. der sonstigen **Verzögerung** der Leistung führen kann; vgl. dazu später unter 8.4.

- Falls die mögliche Leistung fristgerecht, jedoch nicht in der geschuldeten Art und Weise erfolgt, kommt eine Pflichtverletzung hinsichtlich der *Qualität* der Leistung in Betracht, verkürzt lässt sich diese Kategorie der Pflichtverletzung als **Schlechtleistung** umschreiben.
- Während die drei vorgenannten Kategorien das mögliche Schicksal einer *Leistungspflicht* oder einer Pflicht zur Erbringung der geschuldeten Gegenleistung betreffen, können auch nach Vertragsschluss nicht-leistungsbezogene **Schutzpflichten** i. S. des § 241 Abs. 2 BGB bestehen, deren Verletzung wiederum Schadensersatzansprüche auslösen kann, vgl. dazu später in Kap. 9.

Aufgabe 8A: Bitte geben Sie die wesentlichen Kategorien an Pflichtverletzungen innerhalb vertraglicher Schuldverhältnisse nochmals wieder.

Zur konkreten Einordnung, welche Pflichtverletzung in einem Einzelfall vorliegen könnte, bietet sich folgendes gedankliche **Prüfraster** an:

[1] Betrifft die Pflichtverletzung die *vertraglich geschuldete Leistung* (bzw. der Gegenleistung)? Falls ja, anhand der Unterpunkte [a]-[c] weiterprüfen; andernfalls zu Punkt [2] springen:

[a] Ist die Leistung noch möglich? (falls ja, zu [b] springen; ansonsten: Unmöglichkeit der Leistung prüfen)

[b] Wird die Leistung innerhalb vereinbarter Leistungszeit erbracht? (falls ja, zu [c] springen; ansonsten: Verzugs- bzw. Verzögerungssituationen erwägen)

[c] Wird die mögliche, fristgerecht erfolgende Leistung in ordnungsgemäßer Art und Weise erbracht? (falls ja, wird keine die Leistungspflicht betreffende Pflichtverletzung vorliegen, sondern im Zweifel eine ordnungsgemäß erbrachte Leistung; ansonsten: Situationen der Schlechtleistung erwägen, dabei ggfs. vertragspezifische Besonderheiten erwägen [→ Kap. 9 und 10!]).

[2] Betrifft die Pflichtverletzung eine *nicht-leistungsbezogene Pflicht* aus einem Schuldverhältnis, insb. eine Schutzpflicht nach § 241 Abs. 2 BGB? Falls ja, konkrete Rechtsfolgen anhand des Begehrens des Verletzten prüfen, im Zweifel wird Schadensersatz begehrt, dessen rechtliche Beurteilung sich v.a. nach § 280 Abs. 1 BGB bemisst.

8.2 Mögliche Rechtsfolgen bei eintretenden Pflichtverletzungen

Die Rechtsfolgen richten sich nach der *Art* der Pflichtverletzung, vgl. dazu oben 8.1.2, und nach dem *wirtschaftlichen Begehren* des Anspruchstellers.

Beispiel: Verkäufer V schuldet auf Grundlage eines am 16.5.2016 geschlossenen Vertrages Lieferung der verkauften Sache zum 1.6.2016, doch am Morgen des 2.6. hat Käufer K die Ware noch immer nicht erhalten. In dieser Situation kann [1] dem K daran gelegen sein, nach wie vor die gekaufte Ware zu erhalten, und daneben Schäden, die ihm nach dem 1.6.

durch die Dauer der Nichtbelieferung entstehen, ersetzt zu bekommen. Womöglich hat K jedoch [2] an einer Lieferung nach dem 1.6.2016 erkennbar kein Interesse mehr und er möchte entweder unmittelbar vom Vertrag loskommen oder Schadensersatz für Mehrkosten aus einem, inhaltlich vergleichbaren Deckungsgeschäft, das er nach dem 1.6. mit einem Drittanbieter D zu einem höheren Preis abgeschlossen hat, verlangen. Ob die Voraussetzungen vorliegen, die sein jeweiliges Begehren rechtfertigen, ergibt sich aus dem Vertrag bzw. aus dem Gesetzesrecht, soweit dieses ergänzend Anwendung findet, was die sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen anhand des konkreten Sachverhalts erfordert (vgl. dazu Anspruchsprüfung mit Subsumtion sowie entsprechende Hinweise aus Kap. 1 unter 1.4.3). – Soweit K – bei Fortbestand des Vertrages – noch am 2.6. beliefert wird, jedoch die gelieferte Ware qualitativ hinter dem zurückbleibt, was K beanspruchen kann, stellt sich für K die Frage, wie er mit einer solchen Schlechtleistung umgeht. Hier wird in erster Linie [3] das Begehren des K nach Lieferung einer qualitativ einwandfreien Ware („Nacherfüllung“ nach Sachmängelrecht beim Kauf) eine Rolle spielen, hilfsweise das Loskommen vom Vertrag durch Rücktritt, die Minderung des Kaufpreises gegen Behalten der mangelhaften Ware und/oder Schadens- bzw. Aufwendungsersatzansprüche des K.

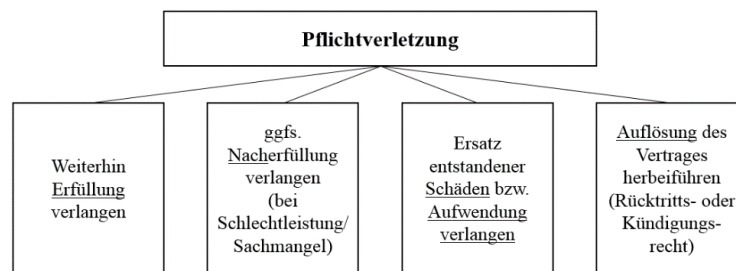


Abbildung: Pflichtverletzung und Schuldnerinteressen am o.g. Beispiel

8.2.1 Das Erfüllungsbegehren des Gläubigers

Bei Unmöglichkeit ist – bei der Stückschuld bzw. der konkretisierten Gattungsschuld, vgl. dazu § 243 Abs. 2 BGB, – der Anspruch auf die Leistung wegen Unmöglichkeit untergegangen. Nach § 275 Abs. 1 BGB wird unter dieser Bedingung der Schuldner von seiner Leistung frei. Der Gläubiger kann nicht länger Erfüllung verlangen, da die Leistung nicht mehr möglich ist.

Bei allen anderen Kategorien von Pflichtverletzungen bleibt eine Erfüllung trotz Vorliegens der Pflichtverletzung zunächst möglich. Hinter diesem Ansatz steckt eine Konzeption des Gesetzgebers, nach welcher das „vertragliche Band“ zwischen Gläubiger und Schuldner, nicht ohne Weiteres durchschnitten werden soll.

Beispiel: Im obigen Beispiel erhält Käufer K die Ware nicht zum geschuldeten Leistungszeitpunkt (1.6.). Daraus folgt für den Regelfall nicht unmittelbar die Unwirksamkeit oder Auflösung des Vertrages durch Gesetz. Vielmehr soll, im Grundsatz, der Gläubiger weiterhin die noch mögliche Leistung fordern können, der Schuldner soll sie weiterhin erbringen müssen und können.

8.2.2 Das Nacherfüllungsbegehren des Gläubigers

Soweit der Gläubiger die Leistung zwar termingerecht, jedoch nicht in der geschuldeten *Qualität* erhält (→ Schlechtleistung), möchte er womöglich die minderwertige Ware zurückgeben und stattdessen eine qualitativ angemessene Ware vom Schuldner ersatzweise nachgeliefert bekommen. Ein solches Nacherfüllungsrecht ist ein modifizierter Erfüllungsanspruch und im speziellen Vertragsrecht für einzelne Vertragstypen geregelt, so etwa im Mängelrecht beim Kaufvertrag und beim Werkvertrag, vgl. dazu §§ 437 Nr. 1, 439 BGB einerseits und §§ 634 Nr. 1, 635 BGB andererseits: Einzelheiten zu vertragstypspezifischen Ausprägungen der Schlechtleistung folgen in Kap. 9 bis 11.

8.2.3 Das Schadensersatzbegehren des Gläubigers– Konzept, Voraussetzungen und Inhalt von Schadensersatzansprüchen

8.2.3.1 Das Schadensersatzkonzept des BGB hinsichtlich (vor-)vertraglicher Pflichtverletzungen

Der Schadenersatzanspruch stellt den praktisch bedeutsamsten *Sekundäranspruch* wegen (vor-)vertraglicher Pflichtverletzungen dar. Der Ersatz von Schäden, die dem Gläubiger aufgrund der Pflichtverletzung entstanden sind, hat im BGB eine ausdifferenzierte Regelung erfahren. Unterschieden wird nach der *Art* des begehrten Schadensersatzes,

die Unterscheidung erfolgt danach, ob der Schadenersatz neben der noch fort-bestehenden Leistung verlangt wird (sog. Schadensersatz **neben** der Leistung) oder er an die Stelle der Leistung treten und diese ersetzen soll (sog. Schadensersatz **statt** der Leistung),

und nach dem *Zeitpunkt*, zu dem die Pflichtverletzung eintritt, was die Wahl der maßgeblichen Anspruchsgrundlagen im BGB beeinflusst.

Abgesehen vom Schadensersatzanspruch wegen **anfänglicher Unmöglichkeit**, der sich nach § 311a Abs. 2 BGB bemisst, vgl. dazu später unter 8.3.2.2 unter [2], gilt für sämtliche anderen Anlässe für Schadensersatz wegen Pflichtverletzung die **zentrale Anspruchsgrundlage des § 280 Abs. 1 BGB** (→ unbedingt lesen, ausgesprochen wichtig!) vgl. dazu sogleich unter 8.2.3.2. Darüber hinaus gilt:

Wegen des – neben dem fortbestehenden Erfüllungsanspruch gewährten – Ersatzes von Schäden, die während und wegen des **Schuldnerverzuges** (§ 286 BGB) eintreten, greifen zusätzlich zu § 280 Abs. 1 BGB die in Abs. 2 der Vorschrift genannten Voraussetzungen, vgl. dazu später unter 8.4.2.3.

Für Ansprüche auf Schadensersatz **statt der Leistung** müssen über § 280 Abs. 1 BGB hinaus gem. Abs. 3 dieser Vorschrift noch die *weiteren Voraussetzungen* entsprechend der Kategorie der jeweils einschlägigen Pflichtverletzung geprüft werden, nämlich

- im Fall der (*nachträglichen*) *Unmöglichkeit*: § 283 BGB mit den dort genannten Verweisungen,
- im Fall der *nicht fristgerecht bzw. nicht ordnungsgemäß erbrachten*, jedoch noch möglichen *Leistung*: § 281 BGB mit den dort genannten Verweisungen sowie
- im Fall der Verletzung von *Schutzpflichten i. S. des § 241 Abs. 2 BGB*: § 282 BGB mit den dort genannten Voraussetzungen.

Beim Schadensersatz statt der Leistung soll der Schadensersatz systematisch an die Stelle der *dann nicht mehr geschuldeten Leistung* treten. Im Falle des § 283 BGB ist dies ohne weiteres ersichtlich, da der Schuldner wegen des Eintritts der Unmöglichkeit von seiner Leistung frei wird und diese nun nicht mehr schuldet, § 275 Abs. 1 BGB. Für die praktisch wichtigen Fälle des § 281 Abs. 1 BGB – geregelt sind darin Verzögerungs- und Schlechtleistungsfälle – knüpft Abs. 4 der Vorschrift den Ausschluss des Anspruchs auf die Leistung an das berechtigte Verlangen des Gläubigers nach Schadensersatz „anstelle“ der Leistung. Im Fall des § 282 BGB ist ebenfalls ein entsprechendes Verlangen des Gläubigers entsprechend § 281 Abs. 4 BGB erforderlich. Betrachten wir zunächst die allgemeinen Voraussetzungen für Schadensersatz gem. § 280 Abs. 1 BGB; die ggfs. erforderlichen zusätzlichen Voraussetzungen kommen unter 8.3 bzw. 8.4 bei den jeweils einschlägigen Kategorien an Pflichtverletzungen.

8.2.3.2 Ausgangspunkt: **Die allgemeinen Voraussetzungen für die Entstehung von Schadensersatzansprüchen nach § 280 Abs. 1 BGB**

Für *sämtliche* Schadensersatzansprüche aufgrund nachträglich entstandener Pflichtverletzungen gelten in jedem Fall die Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 BGB, womöglich treten über § 280 Abs. 2 und 3 BGB noch weitere Voraussetzungen hinzu (vgl. dazu soeben die überblickartigen Anmerkungen unter 8.2.3.1).

Beachte: Nach § 280 Abs. 1 BGB steht dem Gläubiger gegen den Schuldner ein Anspruch auf Schadenersatz zu, wenn

- (1) im Rahmen eines **bestehenden Schuldverhältnisses** i.S. des § 311 BGB
- (2) der Schuldner eine ihm daraus obliegende **Pflicht** objektiv **verletzt**,
- (3) er diese Pflichtverletzung auch subjektiv **zu vertreten** hat (was aufgrund der insoweit greifenden Beweislastumkehr nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB zunächst zu seinen Lasten vermutet wird, wenn und soweit objektiv eine Pflichtverletzung gegeben ist) und schließlich
- (4) dem Gläubiger aus der Pflichtverletzung ein **Schaden entstanden** ist.

Zu diesen Prüfungspunkten einige – auch mit Blick auf die Modulabschlussklausur wichtige – grundsätzliche Anmerkungen entsprechend der o.g. Reihenfolge:

Ad (1): Als **Schuldverhältnisse** i.S. der Regelungen kommen vertragliche Schuldverhältnisse, § 311 Abs. 1 BGB, sowie vorvertragliche Schuldverhältnisse, § 311 Abs. 2 und 3 BGB, dann nur wegen Rücksichtnahmepflichten, in Betracht.

Ausblick: Fehlt an einem solchen Schuldverhältnis, kommen als Grundlage für Schadensersatz in den meisten Fällen höchstens Anspruchsgrundlagen aus dem Deliktsrecht, §§ 823 ff. BGB, in Betracht, die nach den jeweils für sie geltenden Voraussetzungen, jedoch nicht am Maßstab des § 280 BGB zu prüfen sind.

Ad (2): Die **Pflichtverletzung** kann Leistungspflichten und sonstige Pflichten betreffen (Rücksichtnahmepflicht, Schutzpflicht, Treuepflicht, Abnahmepflicht u.a.); vgl. zur Kategorisierung der Pflichten oben 8.1.2.

Ad (4): Unter einem **Schaden** im Sinne des BGB versteht man *jede unfreiwillige Einbuße an rechtlich geschützten Interessen einer Person*. Diese Position wird häufig unmittelbar einer vermögensmäßigen Bewertung zugänglich sein, dann spricht man von *Vermögensschäden* bzw. materiellen Schäden.

Beispiele: Reparaturkosten für die Instandsetzung eines beschädigten Fahrrads (→ die Reparaturkosten sind Sachschäden); ärztliche Heilbehandlungskosten für die fachgerechte Versorgung einer Körperverletzung (→ die Behandlungskosten sind Personenschaden).

Denkbar sind jedoch auch Schadensposten, die nicht unmittelbar vermögensmäßig bewertbar sind, dann spricht man von *Nichtvermögensschäden* oder immateriellen Schäden. Der Ersatz von immateriellen Schäden vollzieht sich letztlich auch über eine vermögensmäßige Betrachtung, da ein Schadensausgleich durch andere Form als Geldbewertung bzw. -zahlung nicht sinnvoll erscheint.

Beispiel: Malermeister M tapeziert auf Grundlage eines Werkvertrages bei Hauseigentümer H das Wohnzimmer. Durch Unachtsamkeit des M fällt die mangelhaft gesicherte Trittleiter um, wodurch der daneben stehende H am Arm verletzt wird. Wegen der aufgrund der Armverletzung erlittenen Schmerzen, die sich als immaterielle Schäden darstellen, kann H als Schadensersatz eine „billige Entschädigung in Geld“ zustehen, vgl. dazu § 253 Abs. 2 BGB. Dass für den Schaden des H im Ergebnis eine Betriebshaftpflichtversicherung des M aufkommen könnte, vgl. zur strukturellen Situation bereits die Ausführungen in Kap. 1 unter 1.2.3, vernachlässigen wir für unsere zivilrechtliche Betrachtung. – Eine andere sinnvolle Form des Ersatzes solcher immaterieller Schäden als durch Geldzahlung, (→ zwei Wochen Urlaub auf Mallorca? 10 Kinogutscheine?, etc.), ist kaum denkbar. Welche Entschädigungshöhe „billig“ i.S. des § 253 Abs. 2 BGB, d.h. im Einzelfall angemessen und gerecht ist, entscheidet im Streitfall das Gericht.

Ad (3): Der Prüfungspunkt, der häufig den meisten Begründungsaufwand erfordert, betrifft das **Vertretenmüssen** einer objektiv vorliegenden Pflichtverletzung durch den Schuldner. Damit ist die **subjektive privatrechtliche Verantwortlichkeit** des Schuldners für die objektiv bestehende Pflichtverletzung angesprochen.

Das Vorliegen des Vertretenmüssens der Pflichtverletzung wird gesetzlich *vermutet*, vgl. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB. Es liegt am Schuldner, Anhaltspunkte dafür vorbringen – und ggfs. vor Gericht beweisen –, dass er die Pflichtverletzung ausnahmsweise doch nicht zu vertreten hat: Die Begründung eines Schadensersatzanspruches nach § 280 Abs. 1 BGB „steht und fällt“ daher mit der Bestimmung des *Maßstabs* des Vertretenmüssens der Pflichtverletzung durch den Schuldner; beachte dazu:

Merke: Was der Schuldner **konkret zu vertreten** hat, bemisst sich – falls keine abweichende Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner vorliegt – grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorschriften der **§ 276 BGB bis § 278 BGB**. Als Anknüpfungspunkte für eine Haftung kommen in Betracht:
 * Haftung für *eigenes* Verschulden (§ 276 BGB; ggfs. mit § 277 BGB oder gem. Sondervorschriften zum Maß je nach Pflichtverletzungskategorie),
 * Haftung für *fremdes* schuldhaftes Verhalten (§ 278 BGB) sowie
 * ggfs. *verschuldensunabhängige* Einstandspflichten bei Vereinbarung der Übernahme von Garantien oder Beschaffungsrisiken, vgl. § 276 Abs. 1 BGB.

Nach § 276 Abs. 1 BGB hat der Schuldner zunächst für *eigenes Verschulden*, das in den Formen des **Vorsatzes** und jeder Form von **Fahrlässigkeit** vorkommt, zivilrechtlich einzustehen. Das ist der gesetzliche Regelmaßstab.

Ergänzung: Gem. § 276 Abs. 2 BGB handelt *fahrlässig*, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Gemeint ist damit der Rechtsverkehr, nicht notwendigerweise der Straßenverkehr. Fahrlässigkeit bedeutet Sorgfaltswidrigkeit unter Berücksichtigung der konkret angesprochenen Verkehrskreise. Der Begriff des *Vorsatzes* ist im BGB nicht definiert, üblicherweise wird darunter das Wissen und Wollen des pflichtwidrigen Erfolgs verstanden (mit „Erfolg“ ist die durch Pflichtwidrigkeit entstandene Verletzung eines Rechts oder Rechtsguts gemeint).

Ein vom Regelmaßstab „Haftung für Vorsatz und jede Form der Fahrlässigkeit“ *abweichender* Haftungsmaßstab kann sich entweder aus dem Gesetz oder aus dem zwischen den Parteien vereinbarten Inhalt des Schuldverhältnisses ergeben:

Das BGB ordnet an verschiedenen Stellen eine *Verschärfung* bzw. eine *Herabsetzung* des Haftungsmaßstabs des Schuldners im Zusammenhang mit einer Störung der Abwicklung des Vertrages an:

Soweit die Störung auf eine Pflichtverletzung des Schuldners zurückzuführen ist, kann es zu einer *Verschärfung* des Verschuldensmaßstabs kommen,

vgl. dazu explizit den Schuldnerverzug gem. § 286 BGB, der gem. § 287 S. 2 BGB zu einer verschuldensunabhängigen Haftung des Schuldners auch für das zufällig eintretende Leistungshindernis führt, vgl. dazu unten 8.4.2.1;

falls die Störung jedoch auf einem Fehlverhalten des Gläubigers beruht, wird der Haftungsmaßstab des Schuldners zu seinen Gunsten *abgesenkt*,

vgl. dazu für den Gläubigerverzug nach §§ 293 ff. BGB ausdrücklich die Bestimmung in § 300 Abs. 1 BGB, wonach der Schuldner während des Gläubigerverzugs nur für Vorsatz

und grobe Fahrlässigkeit, nicht jedoch für „einfache“ bzw. „normale“ Fahrlässigkeit einzustehen hat; Einzelheiten zu Rechtsfolgen des Gläubigerverzugs später unter 8.4.5.2.

Eine Verschärfung des Haftungsmaßstabes kann sich aus dem Inhalt des Schuldverhältnisses ergeben. Der Schuldner haftet verschuldens~~un~~abhängig, wenn

- er das *Beschaffungsrisiko* übernommen hat (was namentlich bei der echten Gattungsschuld gegeben ist, vgl. dazu bereits Kap. 7 unter 7.5.1) oder
- er eine *Garantie*, insbesondere für den Bestand einer (Sach-)Eigenschaft und die rechtlichen Folgen ihres Fehlens, übernommen hat, was eine verschuldensunabhängige Einstandspflicht für das Vorliegen der Eigenschaft bedeutet.

Beispiel für eine Garantieübernahme: Der Verkäufer eines Neu-Kfz übernimmt „drei Jahre Garantie gegen Durchrostung der Karosserie“. Sollte es innerhalb von drei Jahren zu Rostbefall an der Karosserie zu kommen, tritt der Garantiefall ein und der Verkäufer muss die als Garantie versprochene Leistung erbringen. Bei der Garantieübernahme i. S. der Vorschrift handelt es sich um ein *freiwillig* eingegangenes Versprechen des Garantiegebers.

Nach § 278 BGB haftet der Schuldner überdies für ein Fehlverhalten **bestimmter Dritter**, derer er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient. Der Einsatz der Hilfsperson wird mit Bezug auf eine bestehende Pflicht des Schuldners gegenüber einem Gläubiger vorgenommen. An sich ist es Aufgabe des Schuldners, diese Pflicht selbst zu erfüllen. Wenn er dafür nun eine Hilfsperson heranzieht oder ein gesetzlicher Vertreter des Schuldners dies übernimmt, muss der Schuldner für ein Fehlverhalten seiner Hilfsperson bzw. seines gesetzlichen Vertreters in gleichem Maße einstehen als hätte er die Pflicht in eigener Person schuldhaft erfüllt.

Die Vorschrift beruht letztlich auf Gerechtigkeitserwägungen: Wenn es dem Schuldner gestattet wird, Hilfspersonen einzusetzen bzw. dessen gesetzlicher Vertreter tätig wird, muss der Schuldner im Gegenzug die zivilrechtlichen Konsequenzen für deren Fehlverhalten tragen. Denn es geht nicht an, dass er die Vorteile aus einer arbeitsteiligen Wirtschaftsweise zieht, ohne für die damit verbundenen Risiken einstehen zu müssen.

Die zentrale Figur in § 278 S. 1 BGB ist der **Erfüllungsgehilfe**. Erfüllungsgehilfe ist jeder, *der nach den tatsächlichen Gegebenheiten mit Wissen des Schuldners bei der Erfüllung einer diesem obliegenden Verbindlichkeit als dessen Hilfsperson tätig* ist. Für den Begriff des Erfüllungsgehilfen kommt es *nicht* darauf an, ob die Hilfsperson – etwa als Arbeitnehmer – gegenüber dem Schuldner weisungsabhängig ist (obwohl das häufig der Fall sein dürfte), sodass auch selbständige (Sub-)Unternehmer als Erfüllungsgehilfen des Schuldners in Betracht kommen.

Zwischenfazit: Wenn die zu (1)-(4) genannten Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 BGB kumulativ erfüllt sind, ist eine Haftung des Schuldners auf Schadensersatz wegen Pflichtverletzung dem Grunde nach gegeben, falls nicht nach der Art des Schadensersatzes weitere Voraussetzungen nach § 280 Abs. 2 oder 3 BGB hinzutreten müssen. Ein Schadensersatzanspruch nach § 280 Abs. 1 BGB ist unter den vorgenannten Bedingungen wirksam *entstanden*.

Wiederholung: Bei der Darstellung eines Schadensersatzanspruchs nach § 280 Abs. 1 BGB haben wir nochmals sehen können, dass ein solcher Sekundäranspruch nicht bereits mit dem wirksamen Abschluss des Schuldverhältnisses entsteht. Denn zu diesem Zeitpunkt liegt die konkrete Pflichtverletzung in aller Regel noch nicht vor, vielmehr gehen die Vertragsparteien von einer ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages aus.

8.2.3.3 Art, Inhalt und Umfang des Schadensersatzes (§§ 249 ff. BGB)

Mit der **Entstehung** eines Schadensersatzanspruchs, vgl. zuvor 8.2.3.2, gemäß § 280 Abs. 1 BGB dem Grunde nach ist jedoch noch nichts über dessen **Art, Inhalt und Umfang** des Ersatzes ausgesagt. Dazu finden sich weder in den §§ 276 ff. BGB noch in den §§ 280 ff. BGB weiterführende Hinweise. Stattdessen werden im Vorschriftenkomplex der §§ 249-254 BGB in genereller Hinweise Festlegungen über Inhalt und Umfang von Schadensersatzansprüchen, und zwar unabhängig jeweils einschlägigen rechtlichen Grund der Schadensersatzpflicht, getroffen.

Systematischer Hinweis: Die §§ 249 ff. BGB stellen *keine eigene Anspruchsgrundlage* dar, sondern ergänzende Normen („Hilfsnormen“) zur Frage, auf welche Weise die an anderer Stelle angeordnete Schadensersatzpflicht inhaltlich *auszufüllen* ist; vgl. zur unterschiedlichen Funktion von Gesetzesvorschriften schon in Kap. 1 unter 1.4.3.

Den Vorschriften der §§ 249 ff. BGB lässt sich nicht viel Konkretes entnehmen, sodass wir uns an dieser Stelle mit ein paar grundlegenden Aussagen zum Inhalt des Anspruchs des Geschädigten („Schadensersatzgläubiger“) gegen den Schädiger (als regelmäßigem „Schadensersatzschuldner“) begnügen:

- Nach § 249 Abs. 1 BGB ist der Schädiger verpflichtet, *den* wirtschaftlichen Zustand herzustellen, der ohne das schädigende Ereignis bestünde. Es geht im Kern um den Vergleich zweier Zustände: die hypothetische Situation zum Zeitpunkt der Ersatzleistung unter Ausblendung des schädigenden Ereignisses im Vergleich zu dem Zustand, der wegen des Schadenseintritts nun tatsächlich besteht, d. h. juristisch ein sog. Naturalrestitution (also Wiederherstellung des Zustandes, der nunmehr ohne schädigendes Ereignis vorläge) gemäß dem Modell der Differenzhypothese als einem Vergleich zweier Vermögenssituationen.
- In den – praktisch wichtigen – Fällen des Ausgleichs von Sachbeschädigungen und Körperverletzungen kann der Geschädigte vom Schädiger *Ersatz in Geld* verlangen; er muss sich also nicht auf „Reparatur- oder Heilungsversuche“ durch den Schädiger einlassen, vgl. dazu explizit § 249 Abs. 2 BGB.
- Der zu ersetzende Schaden umfasst nach § 252 BGB auch den *entgangenen Gewinn*, der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge erwartet werden konnte – dem Geschädigten wird ausnahmsweise auch eine rein abstrakte Schadensberechnung gestattet (*Beispiel:* Ausfall von Einnahmen des beruflich Selbständigen, der körperverletzungsbedingt zeitweilig seiner Tätigkeit nicht nachgehen konnte).

- *Immaterielle* Schäden werden nach § 253 Abs. 1 BGB nur ersetzt, wenn eine gesetzliche Vorschrift dies anordnet; für den praktisch wichtigsten Fall der Körper- und Gesundheitsverletzung folgt die Ersatzfähigkeit jedoch aus § 253 Abs. 2 BGB sowie aus manchen Sondergesetzen wie etwa dem ProdHaftG.
- Falls der Geschädigte selbst an der Entstehung bzw. der Entwicklung des Schadens mitgewirkt hat, sog. *Mitverschulden*, kann sich der Umfang des vom Schädiger geschuldeten Schadensersatzes nach § 254 Abs. 1 BGB entsprechend dem Verursachungsanteil des Geschädigten reduzieren.

Beispiele: Insbesondere im *Straßenverkehr* kann man Fälle mitwirkenden Verschuldens des Geschädigten gut illustrieren: Der verletzte Fahrzeuginsasse hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt, der verletzte Motorradfahrer keinen Schutzhelm aufgesetzt, etc. die Pflicht „gegen sich selbst“ korrespondiert hier sogar mit entsprechenden Rechtspflichten. – Hingegen wird es von den meisten deutschen Gerichten nicht generell als Mitverschulden gewertet, wenn Radfahrer im Straßenverkehr keinen Fahrradhelm tragen: Weder besteht eine Rechtspflicht noch liegt ein allgemeines Verkehrsbewusstsein vor, wonach das Helmtragen bei Radfahrern dabei zum eigenen Schutz erforderlich ist; anders evtl. die Beurteilung von Sonderfällen des Radsports wie etwa dem Downhill-Biking.

Aufgabe 8B: Malermeister M schließt mit Unternehmer U einen Werkvertrag über den Außenanstrich des Geschäftsgebäudes des U mit einer speziellen wasserresistenten Farbe, deren Sonderherstellung M verspricht. Aus Zeitgründen stellt M die Farbe jedoch nicht selbst her, sondern beauftragt damit den Lackierer L. Nach Erhalt der Farbe durch L nimmt M den Anstrich vor. Bereits wenige Wochen und ein paar Regenschauer später verschmiert der Außenanstrich; Grund dafür ist der ungenügende Schutz der Farbe gegen Witterungseinflüsse: L hatte die Komponenten der Farbe vollkommen unsachgemäß zusammengestellt. Es ist nunmehr ein kompletter Neuanstrich erforderlich, zudem ist ein Anzug des U während eines Regenschauers durch von der Außenwand regenbedingt regelrecht „herabspritzende“ Farbpartikel verunreinigt worden. Bitte beurteilen Sie:

- Welche Ansprüche könnte U wegen dieses Sachverhalts prinzipiell gegen M geltend machen? Bitte zählen Sie auf, indem Sie aus dem Gesetz ableiten. Orientieren Sie sich an der Vorschrift des § 634 BGB.
- Angenommen, U macht wegen seines Anzugs Reinigungskosten in Höhe von 100 € geltend: Liegen im Rahmen der Prüfung eines Schadensersatzes wegen eines werkvertraglichen Sachmangels nach §§ 634 Abs. 4, 280 Abs. 1 BGB die Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 BGB vor?
- M wendet gegen den o.a. Schadensersatzanspruch des U ein, U hätte die Reinigungskosten ohne weiteres vermeiden können, indem er (U) das Geschäftsgelände mit einem speziellen Schutzanzug und nicht mit einem Konfektionsanzug betreten hätte – insoweit sei U „selber schuld“. Wie beurteilen Sie die rechtliche Relevanz dieses Einwands?

8.2.4 Aufwendungsersatzansprüche

Unter Umständen hat der Gläubiger der Leistung *im Vertrauen auf deren Erhalt* Investitionen getätigt, um den Leistungsgegenstand im Wert zu steigern oder diesen besser nutzen zu können. Solche Investitionen lassen sich nicht als Schäden im Rechtssinne qualifizieren, da sie nicht unfreiwillig erfolgten, sondern der Gläubiger sie freiwillig aus einer bestimmten Erwartung heraus vorgenommen hat. Sie werden als **Aufwendungen** bezeichnet. Falls sich nach Abschluss, jedoch vor Beendigung, des Schuldverhältnisses und nach Vornahme der Aufwendung herausstellt, dass der Gläubiger die Sache nicht erhält – v.a. wegen eingetretener Unmöglichkeit der Leistung – erweisen sich die Aufwendungen für den Gläubiger evtl. als **nutzlos**.

(Lehrbuch-)Beispiel: Käufer K kauft beim renommierten Künstler V ein wertvolles, ungewöhnlich dimensioniertes Gemälde zum Preis von 250.000 €, für das er sodann bei Schreiner S einen maßgeschneiderten Rahmen anfertigen lässt (Preis dafür: 10.000 €). Wenn das Bild kurz vor Durchführung des Transports zu K bei einem Brand zerstört wird (Unmöglichkeit i. S. des § 275 Abs. 1 BGB bei der hier gegebenen Stückschuld), wird V von der Leistungspflicht frei. Folglich erhält K weder Eigentum noch Besitz am Gemälde. Er muss freilich, wie wir noch sehen werden, auch nicht den Kaufpreis entrichten. Jedoch hat er 10.000 € für einen konfektionierten Bilderrahmen ausgegeben, den er nun angesichts der genau auf das Gemälde abgestimmten Sondermaße nicht mehr zweckentsprechend einsetzen kann. Darin kann eine nutzlos getätigte Aufwendung liegen.

Nach § 284 BGB kann der Gläubiger für solche vergeblichen Aufwendungen Ersatz verlangen, wenn die genannten Voraussetzungen sowie – abgesehen von der Existenz eines Schadens, an dessen Stelle bei § 284 BGB ja der Begriff der Aufwendung tritt – die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs statt der Leistung (§ 280 Abs. 1, 3 BGB) gegeben sind. *Beachte:* Aufwendungsersatz und Schadensersatz statt der Leistung schließen sich nach dem Wortlaut begrifflich aus: Es kann nur entweder das eine oder das andere geltend gemacht werden.

Im *Ergebnis* bedeutet dies: K kann von V nur dann Aufwendungsersatz in Höhe von 10.000 € für den Bilderrahmen verlangen, wenn V den zur Unmöglichkeit führenden Umstand zu vertreten hat (nach §§ 276, 278 BGB, s.o. zu 8.2.3.2). Das ist etwa der Fall, wenn der Brand auf unachtsamen Gebrauch von offenem Feuer durch Angestellte des V zurückzuführen ist. – Hingegen fehlt es am Vertretenmüssen der objektiv gegebenen Pflichtverletzung (→ Unmöglichkeit!) durch V, falls die Zerstörung des Gemäldes durch einen für V und seine Angestellten unvorhersehbaren Kabelbrand verursacht wurde.

Außerdem wird gem. § 284 BGB ein Ersatz von Aufwendungen nur geschuldet, wenn diese gerade *im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung* gemacht wurden, mithin im Zeitraum zwischen Begründung und Beendigung der Leistungspflicht mit Blick auf die Leistung getätigt wurden, und sie der „*Billigkeit*“ entsprechen. Das Billigkeits-Kriterium will den Schuldner vor unübersehbaren Haftungsfolgen schützen, etwa dann, wenn der Käufer für ein Gemälde (Preis 10.000 €) einen Bilderrahmen zum Preis von 40.000 € anschafft. Bei einem solchen Missverhältnis zwischen dem Wert der Leistung und dem Wert der Aufwendung fehlt es an der Billigkeit.

8.2.5 Das Begehren des Gläubigers nach Auflösung des Vertrages

Allein das Vorliegen einer Pflichtverletzung führt im Regelfall noch nicht zum Wegfall des Vertrages und auch nicht zur Einräumung eines Rücktrittsrechts für den Gläubiger. Ein **gesetzliches Rücktrittsrecht** setzt nach § 323 Abs. 1 BGB neben einer Pflichtverletzung den erfolglosen Ablauf einer vom Gläubiger gesetzten Frist zur Leistung bzw. Nacherfüllung voraus; in besonderen Fällen ist die Fristsetzung entbehrlich, vgl. § 323 Abs. 2 BGB. Im Hinblick auf die Verletzung von Schutzpflichten nach § 241 Abs. 2 BGB knüpft der Gesetzgeber die Gewährung des Rücktrittsrechts in § 324 BGB daran, dass die Fortsetzung des Vertrages dem Gläubiger aufgrund der Pflichtverletzung unzumutbar ist. Vgl. zum Rücktritt – je nach Pflichtverletzung – unter 8.4.3.1 (Verzögerung) sowie in Kap. 9 (Schlechtleistung).

Ergänzung: Im Rahmen der Privatautonomie steht es den Vertragsparteien frei, für einen oder sogar beide Vertragspartner daneben ein *vertragliches* Rücktrittsrecht vorzusehen, dessen Voraussetzungen sich dann nach den im Vertrag gesetzten Bedingungen richtet.

8.3 Die Unmöglichkeit der Leistung

In systematischer Betrachtung ist bei Störungen in der Abwicklung des Schuldverhältnisses zunächst an die Kategorie der **Unmöglichkeit der Leistung** zu denken, obwohl diese in der Praxis eher selten vorkommt. Bei der Unmöglichkeit unterscheidet der Gesetzgeber zwischen der anfänglichen Unmöglichkeit, für die neben § 275 BGB im Wesentlichen § 311a BGB gilt, vgl. dazu später 8.3.2; sowie der nachträglichen Unmöglichkeit, die in einer Reihe von Vorschriften behandelt wird, vgl. dazu später unter 8.3.3. Zunächst muss jedoch geklärt werden, welche Ereignisse überhaupt zur Unmöglichkeit der Leistung führen können, vgl. dazu 8.3.1.

8.3.1 Umstände, die zur Unmöglichkeit der Leistung führen

Unmöglichkeit der Leistung i. S. des § 275 Abs. 1 BGB liegt grundsätzlich nur bei *endgültigen, nicht behebbaren Leistungshindernissen* vor.

Ausblick: Unter bestimmten Voraussetzungen wird ein seiner Art nach nur vorübergehendes Hindernis einem endgültig vorliegenden gleichgestellt; dazu sogleich.

Die aus § 275 Abs. 1 BGB folgende Befreiung des Schuldners von seiner Leistungspflicht (bzw. spiegelbildlich für den Gläubiger formuliert: des Untergangs seines Primäranspruchs auf die Leistung) setzt voraus, dass die Erbringung „*der Leistung*“ unmöglich ist. Dies kann bei originären Stückschulden bzw. bei zur

Stückschuld konkretisierten Gattungsschulden (§ 243 Abs. 2 BGB; vgl. dazu jeweils bereits in Kap. 7 unter 7.5.1) der Fall sein, hingegen *nicht* bei echten Gattungsschulden, bei denen der Schuldner ein Beschaffungsrisiko übernommen hat.

Beispiel: Blumenhändler B schuldet K aus Kaufvertrag Anlieferung und Übereignung von 500 Rosen bestimmter Farbe und Güteklasse. Auf der Fahrt zu K wird B in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem das Fahrzeug schwer beschädigt wird und deshalb die Blumen vernichtet werden. Da eine Bringschuld vereinbart war, bei welcher der Schuldner erst dann alles zur Leistungsbewirkung „seinerseits Erforderliche“, § 243 Abs. 2 BGB, getan hat, wenn er die Ware dem Gläubiger ordnungsgemäß an dessen Wohn- bzw. Geschäftssitz anbietet (→ Kap. 7 bei 7.5.1.4), hat sich die vereinbarte Gattungsschuld noch nicht zur Stückschuld konkretisiert, es liegt somit keine Unmöglichkeit i. S. des § 275 Abs. 1 BGB vor. *Folge:* B schuldet K weiterhin 500 gattungsschuldgemäße Rosen.

Regelbeispiele der Unmöglichkeit wegen eines endgültig vorliegenden Leistungshindernisses sind Fälle der *naturgesetzlichen Unmöglichkeit*, die mit der völligen Zerstörung bzw. Entwertung des sog. Leistungssubstrats einhergehen.

Beispiele: Die verkauften Weinflaschen zerbrechen und der Wein läuft aus; das verkaufte Gemälde verbrennt; das verkaufte Fahrzeug wird bei einem Unfall irreparabel beschädigt.

In Fällen der naturgesetzlichen Unmöglichkeit liegt *objektive* Unmöglichkeit i. S. des § 275 Abs. 1 Alt. 2 BGB vor, da die Unmöglichkeit für jedermann bestünde: Niemand ist mehr in der Lage, das verbrannte Gemälde sinnvoll zu übereignen etc. Der objektiven Unmöglichkeit wird in § 275 Abs. 1 Alt. 1 BGB die *subjektive* Unmöglichkeit gleichgestellt, bei der nur der zur Leistung verpflichtete Schuldner zur Leistung nicht imstande ist, während eine andere Person dies womöglich könnte.

Der Hauptanwendungsfall der subjektiven Unmöglichkeit liegt vor, wenn dem Schuldner der Leistungsgegenstand durch *Diebstahl* o.Ä. abhandengekommen ist und er keine Vorstellung über dessen weiteren Verbleib hat: Beim Diebstahl durch „unbekannte Diebe“ kann man von subjektiver Unmöglichkeit ausgehen, wenn das an sich bloß vorübergehende Leistungshindernis prognostisch als „endgültig eingetreten“ eingeschätzt werden muss.

Wegen des Zeitpunkts, zu dem das zur Unmöglichkeit führende Ereignis eintritt, werden – wie gesehen – die anfängliche und die nachträgliche Unmöglichkeit unterschieden; sämtliche Fälle werden von § 275 Abs. 1 BGB erfasst, d. h.

- die anfänglich-objektive Unmöglichkeit,
- die anfänglich-subjektive Unmöglichkeit,
- die nachträglich-objektive Unmöglichkeit und
- die nachträglich-subjektive Unmöglichkeit,

wobei sich die Rechtsfolgen der einzelnen Formen der Unmöglichkeit entsprechend den jeweils einschlägigen Vorschriften unterscheiden können.

Eine Unmöglichkeit „*durch Zeitablauf*“ ist in besonders gelagerten Fällen denkbar, in denen eine Leistung nach dem vereinbarten Leistungszeitpunkt bzw. -raum *objektiv sinnlos* ist; vgl. dazu, beim absoluten Fixgeschäft, später unter 8.4.3.3. U.a. im Arbeitsrecht spielt diese Form der Unmöglichkeit eine gewisse Rolle.

Wiederholung: Im Regelfall gilt, dass die bloße Nichteinhaltung eines vereinbarten Termins oder einer vereinbarten Frist zur Leistung für sich genommen nichts am Fortbestand der Leistungspflicht des Schuldners ändert.

Ferner kann die Leistung auch aus *Rechtsgründen* unmöglich werden (sog. *rechtliche Unmöglichkeit*). Wenn die Leistung aus dem – wirksam abgeschlossenen – Vertrag aus Rechtsgründen nicht erbracht werden darf, vgl. dazu folgendes

Beispiel (unter Anwendung der vor 2005 geltenden Rechtslage): Staatsangehöriger S, der aus einem Staat außerhalb des EU-Raums stammt, mit dem auch kein Assoziierungsabkommen zur EU besteht, hat in Deutschland einen wirksamen Arbeitsvertrag mit Arbeitgeber A geschlossen. Da S jedoch wider Erwarten keine Arbeitserlaubnis erhält, *darf* A die von S im Übrigen ordnungsgemäß angebotene Arbeitsleistung des S aus Rechtsgründen nicht annehmen.

Der Gesetzgeber hat in § 275 Abs. 2 und Abs. 3 BGB mittlerweile zwei Fallgestaltungen **bloßer Leistungserschwerungen** der Unmöglichkeit nach Abs. 1 wertungsmäßig gleichgestellt, dies durch Anordnung von Leistungsverweigerungsrechten, die praktisch wie eine „Befreiung von der Leistung“ wirken. Es sind dies:

- die sog. *praktische* Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 2 BGB), bei der der Schuldner die Leistung verweigern kann, soweit diese einen Aufwand bedeutet, der auch unter Beachtung des Inhalts des *Schuldverhältnisses* und des § 242 BGB in einem groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Gläubigers steht;

vgl. dazu das *Lehrbuchbeispiel*: Schuldner S überbringt Gläubiger G den kaufvertraglich geschuldeten Ring (Zeitwert: 10.000 €) auf eine Insel in einem tiefen See; bei der Schiffsüberfahrt fällt S der Ring in den See und sinkt auf den Grund desselben. Zwar wäre die Bergung des Ringes mit modernen technischen Mitteln und Geräten heutzutage theoretisch möglich, doch stehen die für eine Bergung anfallenden Kosten (Beispiel: 500.000 €) vollkommen außer Verhältnis zum Leistungsinteresse des G. Unter den Voraussetzungen des § 275 Abs. 2 BGB darf S die Leistung weigern, wodurch er im Ergebnis von seiner Leistungspflicht wegen „praktischer“ Unmöglichkeit frei wird;

sowie

- die sog. *persönliche* Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 3 BGB), bei welcher dem Schuldner – nach einer Abwägung der widerstreitenden Interessen von Gläubiger und Schuldner – die Erbringung der Leistung aus besonderen, in seiner Person liegenden Gründen nicht zugemutet werden soll.

Lehrbuchbeispiel hierzu: Opernsängerin O hat am Abend einen Auftritt in einem Opernhaus (→ Werkvertrag). Am frühen Abend erhält sie die Nachricht, dass ihr Kind bei einem Unfall schwer verletzt wurde und ihm Krankenhaus liegt. Zwar könnte O gesundheitlich singen, da sie selbst nicht an Stimmbändern o.Ä. erkrankt ist (→ *Ergänzung*: Falls O *selbst* entsprechend erkrankt wäre, läge wohl eine Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 BGB aus „gesundheitlichen Gründen“ vor). Jedoch soll ihr gem. § 275 Abs. 3 BGB die Erbringung der werkvertraglich geschuldeten Leistung aus persönlich nicht zugemutet werden, wenn sie aus Sorge um ihr Kind lieber ins Krankenhaus fahren möchte.

8.3.2 Rechtsfolgen der anfänglichen Unmöglichkeit

8.3.2.1 Die Behandlung der *Primäransprüche* (Leistung; Gegenleistung)

Nach § 311a Abs. 1 BGB ist ein Vertrag trotz anfänglicher Unmöglichkeit der Leistung (i. S. des § 275 Abs. 1 BGB) als *wirksam* zu betrachten.

Beispiel: Am Abend des 1.6. gegen 19.00 Uhr schließen V und K im Dorfkrug zu Altenbeken einen Kaufvertrag über das Zuchtpferd Ajax, der Kaufpreis beträgt 12.000 €. Zu diesem Zeitpunkt wissen weder V noch K, dass das Pferd überraschend gegen 18.50 Uhr im Pferdestall des V in Warendorf an einer spontan eingetretenen Nierenkolik verstorben ist. Obwohl um 19.00 Uhr objektiv feststand, dass die Erbringung der Leistung nicht möglich ist (§ 275 Abs. 1 BGB), ist der Vertrag angesichts der Festlegung in § 311a Abs. 1 BGB wirksam abgeschlossen worden.

[1] Eindeutig ist im obigen Beispiel, dass wegen des Eintritts eines Umstands, der zur Unmöglichkeit führt (→ Tod des Pferds), der *Anspruch des Leistungsgläubigers auf die Leistung* erlischt, vgl. § 275 Abs. 1 BGB: Denn Leistungsgegenstand war ein lebendes Pferd, kein Tierkadaver. § 275 Abs. 1 BGB ist die passende Einwendungsnorm gegenüber dem Anspruch auf die Leistung, etwa dem Anspruch gem. § 433 Abs. 1 BGB beim Kaufvertrag, bei Eintritt der Unmöglichkeit.

Am obigen *Beispielsfall*: Der Anspruch des K auf Übereignung des Pferds gem. § 433 Abs. 1 BGB ist wegen Unmöglichkeit der Leistung, § 275 Abs. 1 BGB, untergegangen.

[2] Der Ausschluss der Leistungspflicht des Leistungsschuldners besagt noch nichts über das *Schicksal des Anspruchs auf die Gegenleistung*. Deren Schicksal bestimmt sich bei einem gegenseitigen Vertrag wie dem Kauf nach der Vorschrift des § 326 BGB, die nach ihrem Wortlaut auf § 275 Abs. 1-3 BGB Bezug nimmt: § 326 Abs. 1 Satz 1 BGB ist Einwendungsnorm gegen den Anspruch auf die Gegenleistung, z. B. Kaufpreiszahlung gem. § 433 Abs. 2 BGB beim Kaufvertrag. Danach kommen je nach Einzelfallumständen unterschiedliche Ergebnisse in Betracht:

- Im Regelfall, der in § 326 Abs. 1 BGB ausgeführt wird, führt der aus § 275 Abs. 1-3 BGB folgende Wegfall des Anspruchs auf die Leistung korrespondierend zum Wegfall des Anspruchs auf die Gegenleistung. Dies ist die rechtliche Begründung des traditionellen Kaufmannsmottos „**Ohne Ware kein Geld**“.
- § 326 Abs. 4 BGB versteht sich als logische Fortsetzung des Gedankens aus Abs. 1: Falls der Leistungsgläubiger seine Gegenleistung bereits erbracht, also z.B. den Kaufpreis im Voraus bezahlt hat, kann er diese nach den Grundsätzen über das wirksam ausgeübte Rücktrittsrecht, vgl. dazu §§ 346 ff. BGB, zurückverlangen, falls der Anspruch auf die Leistung nach § 275 Abs. 1 BGB untergeht.
- In Ausnahmefällen(!) behält hingegen der Gläubiger der Gegenleistung – und damit: Schuldner der Leistung – gem. § 326 Abs. 2 BGB seinen Anspruch auf die Gegenleistung, wenn der Umstand, der zur Unmöglichkeit der Leistung geführt hat, auf die Person des Leistungsgläubigers zurückzuführen ist: entweder

weil er sich zum Zeitpunkt, zu der Unmöglichkeit eintritt, in Gläubigerverzug i.S. der §§ 293 ff. BGB befand und der Leistungsschuldner den zur Unmöglichkeit führenden Umstand nicht zu vertreten hat, oder weil er für den zur Unmöglichkeit führenden Umstand weit überwiegend verantwortlich ist.

Ergänzung: § 326 Abs. 2 BGB ist somit Replik, also die „Gegeneinwendung“ des Gläubigers der Leistung gegen die Einwendung aus § 326 Abs. 1 BGB und zugleich Ausdruck eines grundlegenden Gerechtigkeitsgebots: Wenn der Gläubiger der Leistung für den Umstand, dass er diese nicht erhält verantwortlich ist bzw. er die Leistung nicht angenommen hat, obwohl sie ihm in annahmeverzugsbegründender Weise angeboten wurde, muss er seine Gegenleistung erbringen, obwohl er die Leistung nicht erhält.

- In den weiteren Absätzen des § 326 BGB werden weitere Sonderfälle geregelt.

Lösung zum obigen *Beispielsfall*: Wenn wir davon ausgehen, dass Pferdekäufer K sich zum Zeitpunkt des Todes des Pferds weder in Annahmeverzug befand und er auch nicht für dessen Tod verantwortlich ist, bleibt es bei § 326 Abs. 1 bzw. 4 BGB: K muss den Kaufpreis nicht zahlen, da der Anspruch des V auf Kaufpreiszahlung nach § 326 Abs. 1 (i.V.m. § 275 Abs. 1) BGB untergegangen ist; im Falle einer Vorauszahlung kann er den verauslagten Kaufpreis gem. §§ 346 ff. BGB, § 326 Abs. 4 BGB von V zurückverlangen.

8.3.2.2 Die Behandlung etwaiger *Sekundäransprüche* bzw. -rechte

Wie am Pferdekauf-Beispiel gezeigt, führt § 275 Abs. 1 BGB im gegenseitigen Vertrag vielfach dazu, dass der Leistungsgläubiger die Leistung zwar nicht erhält, er im Gegenzug jedoch von seiner Gegenleistung befreit wird. Dieses Ergebnis ist für den Leistungsgläubiger suboptimal, sein Leistungsinteresse wird nicht befriedigt. Deshalb wird er überlegen, ob er nicht *im Wege von Sekundäransprüchen und -rechten* in irgendeiner Weise Ersatz verlangen kann. In Betracht kommen drei Ansätze:

[1] Falls der von der Leistung nach § 275 Abs. 1 BGB befreite Schuldner *aufgrund* des Umstands, der zur Unmöglichkeit geführt hat, einen **Ersatzgegenstand oder einen Ersatzanspruch** (auch *Surrogat* genannt) erlangt, kann der Leistungsgläubiger diesen Ersatzgegenstand bzw. -anspruch gem. § 285 Abs. 1 BGB für sich reklamieren und dessen Herausgabe bzw. Abtretung an sich verlangen.

Am Pferde-Beispiel: Ein Versicherer leistet aufgrund des Todes des Zuchtpferds Ajax an V als dessen Eigentümer (→ Trennungsprinzip zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft!) eine Ersatzsumme von 15.000 €. Diesen Ersatzgegenstand kann letztlich K wegen § 285 Abs. 1 BGB für sich beanspruchen. Er muss dann beim – hier gegebenen – gegenseitigen Vertrag jedoch seine vertraglich vereinbarte Gegenleistung, also 12.000 €, in Ansatz bringen, vgl. dazu § 326 Abs. 3 BGB, sodass er im Ergebnis von V nach Verrechnung noch Zahlung von 3.000 € verlangen kann. Die Vorschrift des § 285 Abs. 1 BGB basiert auf der Idee, dass wenn der Gläubiger die Leistung, die ihm „an sich“ vertraglich zusteht, wegen § 275 Abs. 1 BGB schon nicht erhält, ihm zumindest ein Ersatz, den der Schuldner der Leistung aus Anlass der Unmöglichkeit erhält, zukommen soll.

[2] Falls dem Leistungsgläubiger wegen des Ausbleibens der Leistung aufgrund der Unmöglichkeit ein Schaden entstanden ist, stellt sich die Frage nach **Schadensersatzansprüchen** gegenüber dem Schuldner. Anspruchsgrundlage ist bei der *anfänglichen Unmöglichkeit* allein die Sondervorschrift des § 311a Abs. 2 BGB, dies *ohne* Verweisung auf § 280 BGB. Nach § 311a Abs. 2 BGB kommt Schadensersatz statt der Leistung in Betracht, es sei denn, der Schuldner kannte das Leistungshindernis bei Vertragsschluss nicht bzw. er hat diese Unkenntnis nicht zu vertreten (→ auf Fahrlässigkeit beruhender Unkenntnis). Letztlich läuft das Erfordernis des Vertretenmüssens bei § 311a Abs. 2 BGB auf eine Pflicht des Schuldners zur Verge-
wässerung über die eigene Leistungsfähigkeit hinaus.

Wenn wir für das obige *Pferde-Beispiel* lebensnah davon ausgehen, dass sich V im Laufe des Nachmittags des 1.6. von Warendorf aus auf den Weg nach Altenbeken gemacht hat und zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für eine ernsthafte Erkrankung des Ajax vorlagen, wird man von V nicht verlangen können, er habe sich um 18.59 Uhr – unmittelbar vor Abschluss des Vertrages – nochmals per Telefonanruf oder SMS nach dem Verbleib des Ajax erkundigen müssen. Daher kann sich V im Beispiel mutmaßlich i. S. des § 311a Abs. 2 S. 2 BGB entlasten, weshalb ihn keine Schadensersatzpflicht gegenüber K nach § 311a Abs. 2 BGB trifft. (Offen ist auch noch, worin ein Schaden des K bestehen sollte).

[3] Unter den Bedingungen des § 311a Abs. 2 BGB kommt ausweislich des Wortlauts anstelle eines Schadensersatzanspruches – also alternativ – ein **Aufwendungsersatzanspruch** i. S. des § 284 BGB in Betracht, vgl. dazu oben 8.2.4.

Wegen des engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Vertragsschluss und Tod des Pferdes sind im Beispiel kaum ersatzfähige Aufwendungen denkbar; außerdem würde das Ersatzbegehren am fehlenden Vertretenmüssen der Pflichtverletzung durch V scheitern.

8.3.3 Rechtsfolgen der nachträglichen Unmöglichkeit

Für das Schicksal der *Primäransprüche* auf die Leistung bzw. auf die Gegenleistung kann auf die Ausführungen zu 8.3.2.1 verwiesen werden. Allerdings steht die Leistungsfähigkeit des Schuldners bei Vertragsschluss außer Frage – so dass § 311a Abs. 1 BGB unmaßgeblich ist –, denn im Gegensatz zur anfänglichen Unmöglichkeit tritt bei der nachträglichen Unmöglichkeit der zur Unmöglichkeit führende Umstände erst *nach* Vertragsschluss ein.

Hinsichtlich der *Sekundäransprüche* und -rechte gilt der Anspruch auf Leistung bzw. Abtretung von Ersatzgegenständen bzw. -ansprüchen nach § 285 Abs. 1 BGB auch für die Fälle der nachträglichen Unmöglichkeit. Schadensersatzansprüche bemessen sich allerdings nicht nach § 311a Abs. 2 BGB, sondern nach der allgemeinen Vorschrift des **§ 280 Abs. 1 BGB**, dies regelmäßig i.V.m. §§ 280 Abs. 3, 283 BGB. Der Schadensersatzanspruch kann im Unmöglichkeitssfall ausschließlich auf Schadensersatz *statt* der Leistung zielen, da die Leistung selbst ja wegen § 275 Abs. 1 BGB nicht mehr erbracht werden kann. Nach dem Prüfungsschema zu § 280 Abs.

1 BGB besteht die objektive Pflichtverletzung hier in der Nichtleistung *wegen der Unmöglichkeit*, die Frage des Vertretenmüssens der Pflichtverletzung durch den Leistungsschuldner bemisst sich – anders als bei § 311a Abs. 2 BGB – an der Verantwortlichkeit für den zur Unmöglichkeit führenden Umstand.

Fortentwicklung des Pferde-Beispiels: Angenommen, der Vertrag wurde am 1.6. um 19 Uhr geschlossen und der Tod des Ajax trat gegen 20 Uhr ein, mithin ein Fall nachträglicher Unmöglichkeit. Der geschäftstüchtige K hatte Ajax bereits am 31.5. – in Erwartung des Vertragsschlusses mit V am 1.6. – nachweislich an D für 15.000 € weiterverkauft (→ *Beachte:* Aufgrund der Vertragsfreiheit können Schuldverträge auch über Gegenstände, die erst in der Zukunft produziert oder beschafft werden, wirksam geschlossen werden). Der Weiterveräußerungserlös in Höhe von 3.000 €, den K wegen der Unmöglichkeit nicht gegenüber D realisieren kann, stellt zwar einen Schadensposten „statt der Leistung“ dar, doch steht zunächst die Frage des Vertretenmüssens des zur Unmöglichkeit führenden Umstands des V im Raum: Falls V Ende Mai sorgfaltswidrig trotz entsprechender Krankheitsanzeichen eine tierärztliche Heilbehandlung unterlassen hat, falls es Hinweise auf eine den Tod verursachende Einwirkung auf das Pferd gibt oder falls die Nierenkolik eindeutig auf fehlerhafte Ernährung durch V zurückzuführen ist, wird V den Entlastungsbeweis nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB nicht führen können und demzufolge auf Schadensersatz haften müssen. Andernfalls wird ihm der Entlastungsbeweis gelingen und ein Schadensersatzanspruch des K deshalb nicht zur Entstehung kommen.

Alternativ zum Schadensersatzanspruch statt der Leistung gem. §§ 280 Abs. 1, 3, 283 BGB kommt ein Aufwendungsersatzanspruch nach § 284 BGB in Betracht, wenn die Voraussetzungen sowohl des § 284 BGB als auch – abgesehen vom Schaden, dafür aber der Aufwendung – die der §§ 280 Abs. 1, 3, 283 BGB vorliegen.

Hinweis: Schauen Sie sich bei Interesse auf www.telejura.de die Filme „Der Ring auf dem Grunde des Sees“ und „Die Büffel Boys“ an, die lehrbuchartige Gestaltungen der Unmöglichkeit/Unzumutbarkeit inszenieren und erläutern.

8.4 Verzugs- und Verzögerungssituationen

Komplexer gestalten sich mögliche Rechtsfolgen, wenn der Schuldner die – noch mögliche – Leistung **nicht innerhalb der maßgeblichen Leistungszeit** erbringt. Im Hinblick auf eine „Nichteinhaltung der Leistungszeit“ wird die Situation des Schuldnerverzugs gem. § 286 BGB, dazu sogleich unter 8.4.1 und 8.4.2, von Situationen des verzögerungsbedingten Rücktritts bzw. Schadenersatzes gem. §§ 323 f. BGB bzw. §§ 280, 281 BGB, dazu unter 8.4.3 [dies unter Einschluss sog. Fixgeschäfte], unterschieden. – Doch auch der Gläubiger kann eine Verzögerung der Leistung verursachen, indem er die ordnungsgemäß angebotene Leistung nicht annimmt bzw. an der Entstehung der Leistung nicht, obwohl erforderlich, mitwirkt: Fälle solchen Gläubigerfehlverhaltens werden unter dem Begriff des Annahmeverzugs bzw. Gläubigerverzugs, §§ 293 ff. BGB, unter 8.4.4 und 8.4.5 behandelt.

8.4.1 Die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs, § 286 BGB

Schuldnerverzug, § 286 BGB, liegt vor, wenn der Schuldner die noch mögliche Leistung aus einem von ihm zu vertretenden Grund pflichtwidrig verzögert. Die Rechtsfolgen des Schuldnerverzugs regeln die Folgen des Verzugs auf die *grundsätzlich fortbestehende* Leistungsbeziehung zwischen Gläubiger und Schuldner.

Die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs sind abschließend in § 286 BGB geregelt. Danach muss der Anspruch des Gläubigers auf die – noch mögliche – Leistung aus einem Schuldverhältnis mit dem Schuldner

- voll wirksam entstanden,
- fällig und
- einredefrei sein (→ mit anderen Worten muss der Schuldner leisten *müssen*),
und
- der Gläubiger muss die bisher nicht erbrachte Leistung angemahnt haben (sofern das Erfordernis der Mahnung nicht ausnahmsweise entbehrlich oder durch einen anderen vom Gläubiger initiierten Rechtsakt ersetzt wird), vgl. dazu § 286 Abs. 1 S. 1 und S. 2 sowie Abs. 2 BGB. Schließlich ist als negative Voraussetzung gem. § 286 Abs. 4 BGB zu beachten, dass
- der Schuldner nicht in Verzug kommt, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat; die Führung des Entlastungsbeweises obliegt dem Schuldner.

Klärungsbedürftig sind hinsichtlich der aufgeführten Voraussetzungen des Schuldnerverzugs insbesondere zwei Punkte:

8.4.1.1 Die Mahnung als regelmäßige Verzugsvoraussetzung

Unter einer **Mahnung** versteht man eine an den Schuldner gerichtete eindeutige Aufforderung des Gläubigers, die geschuldete Leistung zu erbringen. Die Mahnung als rechtsgeschäftsähnliche Handlung bedarf grundsätzlich keiner Form, der Begriff „Mahnung“ muss nicht verwendet werden; jedoch muss der Aufforderungscharakter der Mitteilung hinreichend zum Ausdruck kommen (was beispielsweise bei einem bloßen Wunsch [z. B.: „Schön wäre es eben doch, wenn wir die Ware bis zum 12.8. erhalten könnten...“] nicht gegeben ist). In zahlreichen Fällen ist die Mahnung jedoch nach Gesetz ersetzbar oder entbehrlich:

Nach § 286 Abs. 1 S. 2 BGB steht die Einreichung einer Leistungsklage bzw. der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids bei Gericht einer Mahnung gleich.

In § 286 Abs. 2 BGB finden sich praktisch bedeutsame Ausnahmefälle, bei denen der Eintritt des Schuldnerverzugs auch **ohne** Mahnung in Betracht kommt:

Nach der Vorschrift des § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB bedarf es keiner Mahnung, wenn die Leistungszeit durch Gesetz oder vertragliche Vereinbarung nach dem Kalender bestimmt ist.

Beispiele für kalendarische Bestimmung des Leistungszeitpunkts: Leistung „am 12.8.“, „im August“ [→ spätestens zum 31.8.], „zu Fronleichnam 2015“ [→ 3.6.2015]; „im Laufe der 8. Kalenderwoche 2015“ [→ Geschäftswoche vom Mo., 16.2.2015 bis Fr., 20.2.2015].

Nach § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB ist eine Mahnung auch dann entbehrlich, wenn die Leistungszeit an ein vorausgegangenes Ereignis anknüpft und sich kalendermäßig berechnen lässt (*Bestimmbarkeit*, z. B. Zahlung „20 Tage nach Rechnungserhalt“; vgl. für Entgeltforderungen zudem den Sondertatbestand des Verzugseintritts nach § 286 Abs. 3 BGB, der sogleich angesprochen wird).

Ferner ist eine Mahnung nicht erforderlich, wenn der Schuldner die Erfüllung ernsthaft und endgültig verweigert, § 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB, oder wenn besondere Gründe vorliegen, die eine Mahnung – unter Abwägung der wechselseitigen Interessen – entbehrlich erscheinen lassen, vgl. dazu § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB: etwa wenn sich die besondere Dringlichkeit der Leistung aus dem konkreten Inhalt des wirksam geschlossenen Vertrages ergibt, so z. B. bei Reparaturauftrag wegen Wasserrohrbruchs in der Wohnung.

Außerdem kann die Mahnung beim Zugang von Rechnungen wegen Entgeltforderungen gem. § 286 Abs. 3 BGB („30-Tage-Frist“) entbehrlich sein. Ist der Schuldner ein Verbraucher i.S. des § 13 BGB, ist Abs. 3 Satz 2 zu beachten: Notwendig ist dann ein Vorabhinweis auf die Frist und die Rechtsfolgen ihrer Versäumnis.

Zwar ist die Vorschrift des § 286 BGB im Kern *dispositiv*, jedoch ist für abweichende Parteiabreden über den Verzugseintritt § 286 Abs. 5 BGB zu beachten, indem auf die Vorschrift des § 271a BGB verwiesen wird, die – mit dem Zweck der Verbesserung der Zahlungsmoral – eine gesetzliche Beschränkung der Vertragsfreiheit hinsichtlich Zahlungs-, Prüfungs- und Abnahmefristen enthält.

8.4.1.2 Vertretenmüssen und Verzugseintritt

Kein Verzug ohne Vertretenmüssen: Das Vertretenmüssen des Verzugs nach § 286 Abs. 4 BGB wird bei Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen wiederum zu Lasten des Schuldners vermutet, sodass dieser den Entlastungsbeweis führen muss. Was der Schuldner zu vertreten hat, richtet sich nach §§ 276-278 BGB. Im Einzelfall kann das Vertretenmüssen auch aus der Übernahme des Beschaffungsrisikos oder einer Garantie folgen. Der Schuldner hat unter dem Aspekt des Vertretenmüssens sowohl für seine finanzielle Leistungsfähigkeit als auch für seine geschäftlich-betriebliche Organisation einzustehen.

Beispiel: Der gewerblich tätige Verkäufer V hat gegenüber K vertraglich Lieferung zum 30.7. zugesagt. Ende Juli muss er feststellen, dass er den Termin nicht wird einhalten können, da zwei Drittel seiner Mitarbeiter im Urlaub und nahezu das restliche Drittel arbeitsunfähig krank ist. Die ordnungsgemäße Betriebsorganisation ist Aufgabe des V, er hätte bei der Abstimmung der Urlaubsplanung mit der Auftragslage auch außergewöhnliche

Umstände einplanen müssen; daher wird ihm der Entlastungsbeweis hier wohl nicht gelingen. – *Gegenbeispiel*: Aufgrund eines Erdbebens sind weite Teile der Betriebsanlagen des V zerstört, er kann deshalb nur sehr wenige Aufträge abarbeiten. Soweit V keine Beschaffungsrisiken und Garantien übernommen hat, muss er Lieferverzögerungen unter diesen Bedingungen nicht vertreten i. S. des § 286 Abs. 4 BGB, da die rechtzeitige Leistung infolge eines Umstands unterbleibt (→ Naturgewalt), der sich seinem Einfluss entzieht und den er nicht vorhersehen konnte.

8.4.2 Rechtsfolgen des Schuldnerverzugs

Die wesentlichen rechtlichen Folgen des Eintritts des Schuldnerverzugs sind in 8.4.2.1 bis 8.4.2.3 aufgeführt.

Wiederholung: Der Eintritt des Schuldnerverzugs lässt die bestehenden primären Leistungspflichten unberührt!

8.4.2.1 Haftung auch für zufällig eintretende Leistungshindernisse, § 287 S. 2 BGB

Während des Verzugs muss der Schuldner auch für Schäden aus **zufällig eintretenden Leistungshindernissen** einstehen, es sei denn, der Schaden wäre auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten, § 287 S. 2 BGB. Damit verschärft sich der Haftungsmaßstab des Schuldners während des Verzugs gegenüber § 276 BGB.

Beispiele für § 287 S. 2 BGB ergeben sich zumeist aus einer Unmöglichkeit der Leistung, die während des Bestehens des Schuldnerverzugs eintritt: Angenommen Verkäufer V erbringt seine Leistung nicht vereinbarungsgemäß zum 1.6., wodurch im Einzelfall Verzug eintritt. Am 2.6. wird bei ihm die ordnungsgemäß gegen Diebstahl gesicherte Ware von unbekannten Dieben gestohlen oder bei einem durch Blitzschlag entstehenden Brand zerstört. In beiden Fallvarianten beruht der zur Unmöglichkeit führende Umstand (Diebstahl durch Unbekannte; Blitzschlag) nicht auf einer Fahrlässigkeit des V. Dennoch muss er aufgrund der Veränderung des Haftungsmaßstabs, den das Gesetz in § 287 S. 2 BGB zu Lasten des V anordnet, vgl. dazu bereits oben unter 8.2.3.2 ad (3), den zur Unmöglichkeit führenden Umstand vertreten, etwa im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs des Gläubigers nach § 280 Abs. 1 und 3, i.V.m. § 283 BGB.

8.4.2.2 Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen, § 288 BGB

Nach § 288 Abs. 1 BGB sind **Geldschulden** für die Dauer des Verzugs mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, vgl. dazu § 247 BGB, zu verzinsen. Dieser wird halbjährlich durch die Europäische Zentralbank angepasst und beträgt seit 1.7.2016 durchgehend „minus 0,88 Prozent“, sodass Geldschulden während des Verzugs derzeit mit 4,12 % zu verzinsen sind.

Für Entgeltforderungen gegenüber anderen Rechtssubjekten als Verbrauchern i.S. des § 13 BGB gilt ein Zinssatz von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz.

Nach Vertrag ist ggfs. ein höherer Zinssatz möglich, § 288 Abs. 3 BGB, außerdem steht dem Gläubiger der Nachweis eines höheren Schadens offen, § 288 Abs. 4 BGB, der dann als Zinsschadensersatz nach geeigneten Anspruchsgrundlagen geltend gemacht werden kann. Gegenüber Unternehmern i.S. des § 14 BGB als Verzugsschuldnern steht dem Gläubiger einer Entgeltforderung neben dem Verzugszins eine „Entschädigungspauschale“ in Höhe von 40 € zu, vgl. § 288 Abs. 5 BGB. Ob bzw. inwieweit über die Vorschrift des § 288 BGB über die Verzugsverzinsung privatautonom disponiert werden kann, hängt nach Abs. 6 im Wesentlichen davon ab, ob es sich um Entgeltforderungen handelt und ob der Verzugsschuldner Verbraucher i.S. des § 13 BGB ist oder nicht.

Handelsrechtliche Ergänzung: Für Verzögerungssituationen in beiderseitigen *Handelsgeschäften* gem. § 343 f. HGB ist darüber hinaus nach §§ 352, 353 HGB zu beachten, dass – unabhängig vom Verzugsseintritt(!) – Geldschulden mit einem Zinssatz von 5 % bereits **ab Eintritt der Fälligkeit** der Geldforderung zu verzinsen sind, vgl. zum Begriff der Fälligkeit bereits in Kap. 7 unter 7.5.1.5.

8.4.2.3 Anspruch auf Ersatz von Verzugsschäden, § 280 Abs. 1 und 2 BGB

Für die Dauer des Verzugs steht dem Gläubiger gegen den Schuldner ein Anspruch auf Ersatz der ihm **aufgrund des Verzugs entstehenden** Schäden zu, vgl. dazu § 280 Abs. 1 und 2 BGB sowie § 286 BGB.

Merke: Der Anspruch des Gläubigers auf Verzugsschadensersatz (nach § 286 BGB i.V.m. § 280 Abs. 1 und 2 BGB) tritt *neben* den fortbestehenden Anspruch auf die – weiterhin mögliche und geschuldete – Leistung.

Neben den allgemeinen Voraussetzungen für Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 BGB müssen gem. § 280 Abs. 2 BGB die besonderen Voraussetzungen des § 286 BGB vorliegen. Diesbezüglich sind drei Erwägungen wesentlich:

[1] Verzugsschadensersatz wird nur für die *Dauer des Verzugs* geschuldet, d. h. zu dem Zeitpunkt, zu dem der Schuldner dem Gläubiger die noch geschuldete Leistung verspätet, jedoch im Übrigen ordnungsgemäß anbietet, endet der Verzug.

[2] Über §§ 280 Abs. 1, Abs. 2 und 286 BGB kann nur Ersatz solcher Schäden begehrt werden, die *einzig aufgrund des Schuldnerverzugs* entstanden sind.

[3] Da der Verzugsschadensersatzanspruch ausweislich der gesetzlichen Regelung als Anspruch „*neben* der Leistung“ ausgestaltet ist (s.o.), deckt er nur solche Schadensposten ab, die inhaltlich *nicht* an die Stelle der Leistung treten. Zu fragen ist stets, ob der konkrete Schadensposten durch eine spätere Leistung entfallen würde oder ob er endgültig eingetreten ist: Falls er endgültig eingetreten ist, liegt ein über § 280 Abs. 2 BGB prinzipiell erstattungsfähiger Verzugsschaden vor:

Beispiel: Pizzabäcker P, der mit Pizza „aus dem Holzofen“ wirbt, möchte zum 1.6. seine Pizzeria eröffnen und hat von Verkäufer V daher einen entsprechenden Ofen zum Preis von 5.000 € gekauft, der am 31.5. geliefert und aufgebaut werden soll. Durch schlechtes Auftragsmanagement bei V wird der Ofen erst zum 10.6. geliefert. Zwischen dem 1. und 6.6. konnte P sein Geschäft nur betreiben, weil er für 200 € Miete pro Tag kurzfristig einen Ersatzofen von einem Gaststättenausrüster angemietet hat. Am 6.6. hat er „die Faxen dicke“ und kauft kurzer Hand von D einen vergleichbaren Ofen, der ihn jedoch 5.500 € gekostet hat, dafür aber sofort geliefert wird. Kann P von V die Mietkosten in Höhe von 1.200 € (vom 1.-6.6.) sowie die Mehrkosten für das Deckungsgeschäft (500 €) als Verzugsschadensersatz gem. §§ 280 Abs. 1 und 2 sowie 286 BGB verlangen?

Vorliegend soll nur die Erstattungsfähigkeit der Schadensposten nach der genannten Anspruchsgrundlage erörtert werden. (1) Die Kosten für die Miete einer Ersatzsache vom 1. bis 6.6. entfallen auch nicht durch die Lieferung am 10.6.; sie sind daher – einzig und allein – auf den Verzug zurückzuführen und somit als Verzugsschadensersatz nach § 280 Abs. 1, 2 BGB sowie § 286 BGB erstattungsfähig. Hingegen stand am 6.6. (2) keineswegs fest, dass die Leistung des V endgültig ausbleiben bzw. nicht mehr geschuldet wird, da der Vertrag noch nicht aufgelöst war (insbesondere fehlt es an einem wirksamen Rücktritt nach § 323 BGB bzw. an berechtigter Geltendmachung von Schadensersatz statt der Leistung i.S. des 281 BGB). Daher ist die Anschaffung eines weiteren Ofens von einem Drittanbieter keine Disposition, die „neben“ die noch geschuldete Leistung tritt, wenn wir lebensnah davon ausgehen, dass P selbst kein Interesse an zwei Öfen in seinen Räumen hat. Die angefallenen Mehrkosten für das Deckungsgeschäft können daher jedenfalls nicht auf Verzugsschadensersatz nach §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB gestützt werden (s.o.).

Zu den Schadensposten, die typischerweise als **Verzugsschadensersatz** neben der Leistung gem. §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB erstattungsfähig sind, zählen

- die Kosten für die *Beschaffung einer Ersatzgegenstands* während der Dauer und aufgrund des Verzugs,
- der dem Gläubiger während der Dauer des und aufgrund des Verzugs *entgangene Gewinn* sowie
- die *Kosten der Rechtsverfolgung* während des Verzugs, z. B. weitere Mahngebühren, Anwaltsgebühren; hingegen nicht die Kosten für die verzugsbegründende Mahnung, da durch sie außerhalb der Fälle des § 286 Abs. 2 und 3 BGB der Verzugsseintritt erst herbeigeführt wird.

8.4.3 Der Einfluss der Verzögerung der Leistung auf den Fortbestand des (vertraglichen) Schuldverhältnisses

Der Schuldnerverzug lässt den Bestand der Leistungspflicht des Schuldners – und damit den Leistungsanspruch des Gläubigers – unberührt. Je länger die Verzögerung der Leistung andauert, desto eher wird sich der Gläubiger fragen, ob er an der vertraglich geschuldeten, noch möglichen Leistung weiterhin Interesse hat und ob er deshalb an ihr und am Vertrag noch festhalten möchte. In der Verzögerungssituation kann der Leistungsgläubiger den Wegfall der Leistungspflicht herbeiführen – und damit: das vertragliche Band mit dem Schuldner auflösen –, indem

- er entweder vom **Vertrag zurücktritt**, was nach § 323 BGB insbesondere, soweit ihm kein vertragliches Rücktrittsrecht eingeräumt wurde, einen gesetzlichen Rücktrittsgrund voraussetzt, vgl. zum Rücktritt sogleich unter 8.4.3.1, oder
- wirksam **Schadensersatz statt der Leistung** wegen nicht fristgerecht erbrachter Leistung nach §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB geltend macht, wodurch der Anspruch auf die Leistung nach § 281 Abs. 4 BGB entfällt, da ja der begehrte Schadensersatz an die Stelle („statt“) der Leistung tritt; vgl. dazu unter 8.4.3.2.

In grundsätzlicher Weise klärt § 325 BGB, dass Schadensersatz und Rücktritt sogar nebeneinander geltend gemacht werden können. In der Sondersituation sog. **Fixgeschäfte** kann der Gläubiger den Wegfall der vertraglichen Pflichten auf noch vereinfachte Weise herbeiführen, vgl. dazu später unter 8.4.3.3.

8.4.3.1 Das Rücktrittsrecht wegen Leistungsverzögerung

Nach § 323 Abs. 1, Var. 1 BGB kann dem Leistungsgläubiger im gegenseitigen Vertrag ein Rücktrittsrecht zustehen, wenn der Schuldner **eine fällige Leistung nicht erbringt**. Da bei Unmöglichkeit der Leistung der Anspruch auf die Leistung gem. § 275 Abs. 1 BGB schon von Gesetzes wegen erlischt, vgl. oben 8.2.1, also die Ausübung eines Rücktrittsrechts nicht erforderlich ist, kann mit der Formulierung in § 323 Abs. 1 Alt. 1 BGB nur die Leistungsverzögerung gemeint sein. Die *nicht vertragsgemäße* Leistung, umschrieben als „Schlechtleistung“, wird in § 323 Abs. 1, Var. 2 BGB gesondert angesprochen, vgl. dazu später unter 8.5.2.

Die Voraussetzungen eines solchen Rücktrittsrechts sind nach § 323 BGB regelmäßig – und vollkommen unabhängig von denen des Verzugs, § 286 BGB –

- das Vorliegen einer Leistungsverzögerung
- im Rahmen eines gegenseitigen Vertrags, wobei
- der Gläubiger dem Schuldner grundsätzlich eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben muss und
- die Frist erfolglos verstrichen sein muss (wenn und soweit die Fristsetzung nicht ausnahmsweise nach § 323 Abs. 2 BGB entbehrlich ist).

Ausnahmsweise kommt ein Rücktrittsrecht wegen Leistungsverzögerung gem. § 323 Abs. 6 BGB nicht in Betracht, wenn der Umstand, der den Gläubiger zum Rücktritt berechtigen würde, von ihm selbst zu verantworten ist oder wenn der vom Schuldner nicht zu vertretende Umstand zu einer Zeit eintritt, zu welcher sich der Gläubiger in Annahmeverzug gem. §§ 293 ff. BGB befindet.

Die *Fristsetzung* muss eine bestimmte und eindeutige Aufforderung zur Leistung enthalten. Die Frist muss angemessen sein, was sich nach den jeweiligen Einzelfallumständen bemisst; bei besonderer und erkennbarer Eilbedürftigkeit kann sogar eine Frist von nur ein bis zwei Tagen ausreichend sein.

Beachte: Bei Vorgabe einer zu kurz bemessenen Frist wird eine objektiv angemessene in Gang gesetzt, die Beurteilung erfolgt im Streitfall durch das angerufene Gericht. In der

Fristsetzung nach § 323 Abs. 1 BGB kann ausnahmsweise zugleich eine Mahnung i. S. des § 286 Abs. 1 S. 1 BGB zu erblicken sein.

An sich verfolgt der Gesetzgeber mit dem Erfordernis der Fristsetzung nach § 323 Abs. 1 BGB das Ziel, dem Schuldner einen letzten Hinweis zu geben, dass der Fortbestand des Vertrages ernsthaft in Gefahr ist, wenn er weiterhin nicht liefert (1. Var.) bzw. nicht ordnungsgemäß liefert (2. Var.). In § 323 Abs. 2 BGB werden gleichwohl Fälle behandelt, in denen die Fristsetzung ausnahmsweise *entbehrlich* ist. Neben dem in Nr. 2 der Vorschrift regeltem – relativen – Fixgeschäft, vgl. dazu sogleich im Einzelnen unter 8.4.3.3 – ist die Fristsetzung bei der ernsthaften und endgültigen Erfüllungsverweigerung durch den Schuldner (Nr. 1) sowie in besonders gelagerten, nicht näher bezeichneten Ausnahmefällen (Nr. 3) möglich.

Beachte: Die Entstehung des Rücktrittsrechts nach § 323 Abs. 1 BGB hängt – anders als beim Anspruch auf Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 BGB – *nicht* davon ab, dass der Schuldner die Pflichtverletzung zu vertreten hat!

Das Rücktrittsrecht ist ein Gestaltungsrecht, es bedarf somit der Ausübung durch den Rücktrittsberechtigten durch Erklärung, vgl. § 349 BGB. In Folge der wirksamen Ausübung wird das bestehende vertragliche Schuldverhältnis aufgelöst, es wandelt sich in ein sog. **Rückgewährschuldverhältnis**, vgl. dazu §§ 346 ff. BGB.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass die wechselseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren sind und im Ergebnis so getan wird als habe es den Vertrag nie gegeben. Soweit eine Rückgewähr nicht möglich ist, kann Wertersatz an die Stelle treten.

8.4.3.2 Schadensersatz statt der Leistung wegen Leistungsverzögerung

Der Anspruch auf Schadensersatz *statt* der Leistung wegen Leistungsverzögerung richtet sich nach §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1 Var. 1 BGB. Dabei stellt sich für die Situation der Leistungsverzögerung die Vorschrift des § 281 BGB auf Schadensersatz als Komplementärvorschrift zum Rücktritt nach § 323 BGB dar.

Merke: Für den Ersatz verzugsbedingter Schäden *neben* der Leistung gilt, wie schon gesehen, die Anspruchsgrundlage des § 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB! Die korrekte Auswahl der Anspruchsgrundlage und in diesem Zusammenhang die korrekte Bestimmung der Art des begehrten Schadensersatzes (statt der Leistung oder neben der Leistung?) ist deshalb so bedeutsam, weil die Voraussetzungen für die einzelnen Schadensersatzansprüche vom Gesetzgeber bewusst unterschiedlich ausgestaltet wurden und diese nicht unterlaufen werden dürfen.

Neben den allgemeinen Voraussetzungen für Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 BGB (→ vgl. o. 8.2.3.2, daher Erfordernis des *Vertretenmüssens* der Pflichtverletzung) müssen somit die Voraussetzungen des § 281 Abs. 1, 1. Var. BGB erfüllt sein, was neben dem Vorliegen einer Leistungsverzögerung die Setzung einer angemessenen Frist sowie deren fruchtlosen Ablauf, soweit nicht die Setzung einer solchen Frist ausnahmsweise nach § 281 Abs. 2 BGB entbehrlich ist erfordert. Ein

berechtigtes Schadensersatzverlangen des Gläubigers nach Schadensersatz statt der Leistung führt gem. § 281 Abs. 4 BGB dazu, dass der Primäranspruch auf die Leistung ausgeschlossen ist – die Leistung kann vom Schuldner ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erbracht, vom Gläubiger nicht mehr verlangt werden. Zu den Schadensposten, die bei Leistungsverzögerungen typischerweise als Schadensersatz statt der Leistung erstattungsfähig sind, zählen Mehrkosten, die dem Gläubiger durch die Vornahme eines angemessenen Deckungsgeschäfts entstehen sowie der dem Gläubiger entgangene Gewinn aus einer wegen des Ausbleibens der Leistung nun nicht durchführbaren Weiterveräußerung.

In dem unter 8.4.2.3 angeführten *Pizzaofen-Beispiel* kann P die Mehrkosten für den Deckungskauf daher eventuell als Schadensersatz statt der Leistung nach §§ 280 Abs. 1, 3 i.V.m. § 281 Abs. 1 BGB geltend machen, wenn und soweit die Voraussetzungen gegeben sind. Zweifel ergeben sich beim Erfordernis aus § 281 Abs. 1 BGB: Eine Fristsetzung durch P gegenüber V ist nicht erkennbar, ebenso wenig Gründe, weshalb die Fristsetzung nach § 281 Abs. 2 BGB ausnahmsweise entbehrlich sein sollte (der Umstand, dass P angesichts der ausbleibenden Leistung „die Faxen dicke“ hat, genügt selbstverständlich nicht). Als Fazit bleibt festzuhalten: Der von P eigenmächtig vorgenommene Deckungskauf, bei dem weder die Voraussetzungen des § 323 Abs. 1 BGB noch des Abs. 2 erfüllt sind, berechtigt ihn nicht zum Ersatz der angefallenen Mehrkosten unter Wegfall der Leistungspflicht des V. P wird nun zwei Öfen abnehmen und bezahlen müssen.

8.4.3.3 Fixgeschäfte

Wir wissen, die Nichteinhaltung eines Leistungszeitpunktes lässt die Primäransprüche im Regelfall unberührt: Im gegenseitigen Vertrag muss der Schuldner seine Leistung nach wie vor erbringen, gleiches gilt für die vom Leistungsgläubiger geschuldete Gegenleistung. Dennoch gibt es Ausnahmefälle, in denen der Leistungsgläubiger sein Leistungsinteresse erkennbar dermaßen eng an die Einhaltung der Leistungszeit gebunden hat, dass eine verspätete Leistung jedenfalls für ihn keinen Sinn mehr ergibt. Rechtsgeschäfte, bei denen ein solchermaßen „fixer“ Leistungszeitpunkt vereinbart ist, können in zwei Ausprägungen vorkommen.

Beim sog. **absoluten Fixgeschäft** ist jede spätere Leistung objektiv sinnlos, da für jeden erkennbar ist, dass mit ihr nicht mehr erfüllt und sie deshalb nicht nachgeholt werden kann. Die Nichteinhaltung eines absoluten Fixgeschäfts führt unmittelbar zur Unmöglichkeit der Leistung „der Zeit nach“ – der Gläubiger braucht nichts weiter zu veranlassen, um vom Vertrag loszukommen.

Beispiel: Für eine Hochzeitsfeier, zu der zahlreiche Gäste aus allen fünf Kontinenten erscheinen, wird ein Hochzeitsfotograf zu 14 Uhr engagiert (→ Werkvertrag). Wenn der Fotograf diesen Termin versäumt und anbietet, später nochmals zu kommen, ist die Erbringung der Leistung nicht mehr möglich i. S. des § 275 Abs. 1 BGB, da die Unzumutbarkeit, alle „über den Erdball verstreuten“ Gäste zu einem späteren Zeitpunkt erneut für ein Foto zu versammeln, einem endgültigen Leistungshindernis gleichkommt.

Demgegenüber zeichnet sich das **relative Fixgeschäft** dadurch aus, dass für den Gläubiger die Einhaltung des vereinbarten Leistungszeitpunkts subjektiv wesentlich ist und der Schuldner dies vor Vertragsschluss erkennen kann. Wird der Leistungszeitpunkt nicht eingehalten, kann der Gläubiger gem. § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB auch ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und so den Vertrag auflösen. Anders als beim absoluten Fixgeschäft muss der Gläubiger hier also noch ein Gestaltungsrecht (Rücktritt) gem. § 349 BGB ausüben, um vom Vertrag loszukommen.

Beachte: Für die Anwendbarkeit des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB genügt der Umstand, dass überhaupt ein Leistungszeitpunkt vereinbart wurde, für sich genommen noch nicht. Denn dies führt nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB „nur“ zur Entbehrlichkeit der Mahnung für den Verzugseintritt. Vielmehr muss die termin- bzw. fristgerechte Leistung für den Gläubiger wesentlich sein und dies muss für den Schuldner bei Vertragsschluss erkennbar sein, dies durch Mitteilung oder aufgrund der Begleitumstände des Vertragsschlusses. Wesentlich ist die Einhaltung von Termin bzw. Frist für den Gläubiger namentlich dann, wenn er im Vertrag den Fortbestand seines Leistungsinteresses erkennbar an die Einhaltung gebunden hat, sodass das Geschäft damit „stehen und fallen“ soll. Im geschäftlichen Verkehr können Vertragsklauseln wie „fix“, „genau“ oder „prompt“, die in Verbindung mit einer näher bestimmten Leistungszeit verwendet werden, darauf hindeuten.

8.4.4 Die Voraussetzungen des Gläubigerverzugs

Die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistung kann auch durch ein Fehlverhalten des Gläubigers gestört werden, falls der Gläubiger die Erbringung der Leistung verhindert, was nur sehr selten vorkommen wird, oder er die ordnungsgemäß angebotene Leistung nicht annimmt bzw. eine andere, seinerseits erforderliche Mitwirkungshandlung, die für die ordnungsgemäßen Erfüllung erforderlich ist, unterlässt. Die in §§ 293 ff. BGB geregelten Voraussetzungen des **Gläubigerverzugs** – gleichbedeutender Begriff: Annahmeverzug – sind:

- die Leistungsberechtigung des Schuldners,
- die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit und -möglichkeit des Schuldners (vgl. dazu § 297 BGB),
- ein ordnungsgemäßes Angebot des Schuldners gegenüber dem Gläubiger (§ 294 BGB), sofern ein solches nicht ausnahmsweise nach §§ 295 f. BGB entbehrlich ist sowie
- die Nichtannahme der Leistung bzw. die Verweigerung einer für die Erfüllung erforderlichen Mitwirkungshandlung seitens des Gläubigers.

Beachte: Für den Eintritt des Gläubigerverzugs ist es *unerheblich*, ob der Gläubiger die Nichtannahme der Leistung zu vertreten hat oder nicht. Da ihn in seiner Eigenschaft als Gläubiger(!) keine Pflichten treffen, vgl. dazu bereits oben unter 8.1.1, kann er solche auch nicht verletzen, sodass sich die Frage des Vertretenmüssens einer Pflichtverletzung gar nicht stellt.

Hinsichtlich der Voraussetzungen sind noch ein paar Anmerkungen zum Angebot des Schuldners angezeigt. Grundsätzlich ist ein *tatsächliches* Angebot des Schuldners erforderlich nach § 294 BGB, d. h. er muss die Leistung dem Gläubiger in gegenständlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht so wie geschuldet anbieten. Ausnahmsweise ist ein solches tatsächliches Angebot entbehrlich:

[1] Nach § 295 BGB genügt ein *wörtliches* Angebot, wenn

- der Gläubiger erklärt hat, er werde die Leistung nicht annehmen oder
- zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des Gläubigers erforderlich ist (hier genügt die an den Gläubiger gerichtete verbale Aufforderung zur Vornahme).

Beispiel: Bei vereinbarter Holschuld holt der Gläubiger den Gegenstand nicht ab; hier genügt die Aufforderung zur Abholung.

[2] Falls der Gläubiger seine zu einem bestimmten bzw. kalendermäßig berechenbaren Zeitpunkt vorzunehmende Handlung unterlässt, ist nach § 296 BGB überhaupt kein Angebot – noch nicht einmal ein wörtliches – erforderlich.

8.4.5 Die Rechtsfolgen des Gläubigerverzugs

Durch den Eintritt des Gläubigerverzugs verschlechtert sich die Rechtsstellung des Gläubigers, diejenige des Schuldners verbessert sich entsprechend: Die wichtigsten Rechtsfolgen nach §§ 300-304 BGB werden nachfolgend angesprochen.

8.4.5.1 Der Übergang der Leistungsgefahr nach § 300 Abs. 2 BGB

Zwar tritt in der Situation des Gläubigerverzugs eine Konkretisierung der Gattungsschuld nach § 243 Abs. 2 BGB regelmäßig bereits mit dem – nicht angenommenen – tatsächlichen Angebot ein. Soweit ein wörtliches Angebot genügt oder ein solches entbehrlich ist (Fälle des §§ 295, 296 BGB, s. o. unter 8.4.4 a.E.), fehlt es jedoch bei Bring- oder Schickschulden an der entscheidenden Handlung des tatsächlichen Anbietens und die Konkretisierung steht noch aus. Für diese Fälle bringt § 300 Abs. 2 BGB zum Ausdruck, dass die Leistungsgefahr, also die Gefahr, dass die Leistung endgültig ausbleibt, unabhängig von § 243 Abs. 2 BGB bereits mit Eintritt des Gläubigerverzugs übergeht. Darin liegt dann eine „Quasi-Konkretisierung“.

8.4.5.2 Veränderter Haftungsmaßstabs des Schuldners, § 300 Abs. 1 BGB

Während des Gläubigerverzugs hat der Schuldner nicht mehr – vgl. den in § 276 Abs. 1 und 2 BGB angesprochenen Regelmaßstab – jede Fahrlässigkeit, sondern neben Vorsatz nur noch *grobe* Fahrlässigkeit zu vertreten, vgl. § 300 Abs. 1 BGB.

Hinweis: Die Vorschrift hat Bedeutung in Fällen erlangt, in denen es während des Gläubigerverzugs zum Untergang der geschuldeten Leistung, namentlich durch Eintritt eines zur Unmöglichkeit führenden Umstands, kommt. Verursacht der Bringschuldner, nachdem er den Gläubiger zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort nicht angetroffen hat, auf dem Rücktransport der Ware schuldhaft einen Verkehrsunfall, bei dem die Ware zerstört wird (→ Unmöglichkeit der Leistung, § 275 Abs. 1 BGB; im Falle von Gattungsschulden wird Konkretisierung nach § 243 Abs. 2 BGB durch tatsächliches Leistungsangebot eingetreten sein, ggfs. greift § 300 Abs. 2 BGB, s.o.), kann er vom Gläubiger zwar nach wie vor auf Schadensersatz statt der Leistung nach §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB in Anspruch genommen werden. Doch beim Vertretenmüssen der Pflichtverletzung ist der veränderte Haftungsmaßstab zu beachten: Hat der Schuldner den o.g. Verkehrsunfall „nur“ leicht fahrlässig herbeigeführt, fehlt es wegen der in § 300 Abs. 1 BGB angeordneten Verschiebung des Haftungsmaßstabes zu Gunsten des Schuldners am Vertretenmüssen. Der Gläubiger erhält in diesem Fall keinen Schadensersatz.

8.4.5.3 Ersatz von Mehraufwendungen, § 304 BGB

Zwar führt der Eintritt des Gläubigerverzugs nicht zu einem Schadensersatzanspruch des Schuldners; ebenso wenig wird dadurch die Schuldart verändert, also z. B. keine Verschiebung der Bringschuld zur Holschuld. Dennoch fällt beim Schuldner verzugsbedingt ein Mehraufwand an. Daher gewährt § 304 BGB dem Schuldner einen verschuldensunabhängigen Anspruch auf Ersatz für Mehraufwendungen, die ihm nicht nur für das erfolglose Angebot, sondern auch für die Erhaltung des geschuldeten Gegenstands während der Dauer des Gläubigerverzugs entstehen.

Beispiele: Kosten für die Anfahrt zum Übergabetermin, der sich wegen des Gläubigerverzugs als nutzlos herausstellt; Kosten für die Anmietung von Lagerkapazitäten zur Aufbewahrung der Sache während des Gläubigerverzugs, etc.

8.4.5.4 Weitere Rechtsfolgen nach BGB

Nach § 301 BGB wird der Geldschuldner während des Gläubigerverzugs von jeder Zinspflicht befreit. § 302 BGB bewirkt eine Erleichterung der Rechtsstellung des Schuldners im Hinblick auf eine vertragliche Verpflichtung zur Herausgabe von Nutzungen; vgl. zum Begriff der Nutzungen die Definition in § 100 BGB.

8.4.5.5 *Ausblick:* Annahmeverzug im Handelskauf

Für Kaufverträge **im kaufmännischen Verkehr** stellen sich die Rechtsfolgen nach BGB häufig als nicht hinreichend flexibel dar; daher sind in § 373 HGB – neben den weiterhin geltenden BGB-Rechtsfolgen (vgl. dazu § 374 HGB) – weitere Handlungsoptionen für den Verkäufer gegenüber dem säumigen Käufer vorgesehen, die im Kap. 10 bei besonderen Gestaltungen des Kaufs behandelt werden.